العام الجامعي
2026 / 2027

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

مذكرات ومراجعات تفاعلية معتمدة

• المذكـرة الأساسيـة •

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

• تأصيل تحليلي • تطبيقات قضائية • صياغة أكاديمية

القضايا الفقهية المعاصرة

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثانية

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

القضايا الفقهية المعاصرة:

القضايا الآتية

البطاقة الائتمانية	الشرط الجزائي	الإجارة	المناقصة



البطاقة الائتمانية وشبهة الربا:

١ التعريف والتاريخ والأنواع والمنافع
٢ أقسام البطاقات وحكمها
٣ أثر الشروط الباطلة على صحة العقد
٤ التكييف الفقهي للعلاقات بين الأطراف
٥ الأحكام الفقهية للرسوم والعمولات
٦ شراء الذهب والفضة بالبطاقة

١ التعريف:

البطاقة لغةً: الوَرَقة، وهي رُقعة صغيرة يُثبت فيها مقدار ما تُجعل فيه.

الائتمان لغةً: مأخوذ من الأمان وهو ضد الخوف، وفي الاصطلاح الاقتصادي: منح دائن لمدين مهلة من الوقت يلتزم المدين بانتهائها بدفع قيمة الدين.

التعريف الفقهي: عرّفها علماء مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأنها: مستند يعطيه مصدره — والمراد به: البنك أو المؤسسة المالية التي أصدرت البطاقة — لشخص طبيعي أو اعتباري بناءً على عقد بينهما، يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند — والمراد به: التاجر أو مقدم الخدمة الذي يقبل البطاقة — دون دفع الثمن حالًا، لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ومن أنواعه ما يمكّن من سحب نقود من المصارف على حساب المصدر.

التعريف الاقتصادي: بطاقة خاصة يصدرها المصرف لعميله تمكنه من الحصول على السلع والخدمات من محلات معينة، ويقدم بائع السلع الفاتورة الموقعة إلى المصرف مصدر الائتمان فيسدد قيمتها له، ويقدم المصرف للعميل كشفًا شهريًا.

MARA 01105405478

المختار: **التعريف الفقهي** ؛ لشموله جميع أنواع البطاقات المصرفية، ويظهر منه أن بطاقات الائتمان ليست نقودًا في حد ذاتها، بل وسيلة من وسائل الدفع تقوم مقام النقود.

2 نبذة تاريخية والجهات المصدرة:

نشأة البطاقة: ظهرت الحاجة إليها في مطلع القرن العشرين في أمريكا عندما أصدرت شركات البترول بطاقات لعملائها، وأول من أصدرها بنك ناشيونال فرانكلين عام ١٩٥٢م، ثم البنك الأمريكي عام ١٩٥٨م، ثم أمريكان إكسبريس عام ١٩٥٨م، ثم نشطت الفكرة عام ١٩٧٠م، ثم تكونت جمعية تعاونية أصدرت البنوك بواسطتها بطاقة فيزا.

الجهات المصدرة: يتولى إصدار البطاقات العالمية جهتان: أمريكان إكسبريس وفيزا.

3 أنواع البطاقات المصرفية ووصفها:

1. **بطاقات الحساب الجاري:** مرتبطة مباشرة بالسحب من الرصيد، بمعنى: أن العميل يدفع بها من ماله الموجود في البنك، ولا يقترض من البنك شيئًا، ولا تُعد بطاقة ائتمان وليست المقصودة.
2. **بطاقات الائتمان:** تُقسم بحسب مزاياها أو مادتها أو جهتها المصدرة أو وجود الغطاء، والتقسيم الأخير هو المؤثر في التصوير والتكييف، ووجود الغطاء وعدمه مؤثر في الحكم؛ لأن الائتمان معناه: أن البنك يتكفل بالدفع عن العميل، ثم يرجع على العميل لاحقًا.

من حيث الشكل: عادية وذهبية وبلاتينية، ولا فرق بينها في آلية الإصدار والاستخدام، غير أن بعضها يتمتع بمزايا إضافية كالتأمين ضد الحوادث والتأمين الطبي وضمانات البضائع.

4 منافع البطاقات وأثرها الاقتصادي:

1. **حامل البطاقة:** تسهيلات نقدية من أي عضو في المنظمة، واستخدام أجهزة الصرف الآلي، وتسهيل حجز الفنادق والشراء البريدي، والاستخدام محليًّا ودوليًّا دون حمل النقد.
2. **التاجر:** جذب عملاء جدد، وميزة تنافسية، وتخفيف مخاطر الاحتفاظ بالنقد، والاستفادة من الحملات الدعائية.

3. **البنك المصدر:** توظيف أمواله، وضم عملاء، واضطرار الحاملين والتجار لفتح حسابات، والانتشار العالمي.

إيجابيات الأثر الاقتصادي: توسع السوق وزيادة الطلب، وتوفير الأمان، وزيادة السيولة.

سلبيات الأثر الاقتصادي: وقوع مشاكل اقتصادية لمنح الائتمان لغير المؤهلين، وزيادة الفوائد على القروض، وإمكانية التزوير، وتوجيه الديون إلى الحاجات الاستهلاكية غير الإنتاجية.

المسألة الأولى: أقسام بطاقات الائتمان وحكمها:

البيان وسبب الخلاف: البطاقة الائتمانية ليست نوعًا واحدًا، بل أنواعها مختلفة، والحكم الشرعي يختلف باختلافها، والمعيار الذي يهمنا هنا هو: هل يقابل استخدام البطاقة رصيد موجود للعميل في البنك، أم لا؟ فالبطاقة المغطاة يدفع بها العميل من رصيده الخاص، فلا يقترض من البنك شيئًا، وإنما يأمر البنك بأن يدفع عنه من ماله هو، أما غير المغطاة فإن البنك يدفع عنه من مال البنك، فيصبح العميل مدينًا للبنك، ثم يسدد له لاحقًا، وربما مع زيادة إن تأخر، ومن هنا نشأ الخلاف: المغطاة لا إشكال فيها لأنها لا تخرج عن كونها وسيلة دفع من مال صاحبها، أما غير المغطاة فلأنها تنطوي على دين وزيادة محتملة، دخلت في نطاق مسائل الربا، وفي هذا القسم الثاني تفصيل بحسب طريقة السداد.

1. القسم الأول: البطاقات المغطاة:

تعريفها: يشترط مصدرها على حاملها إيداع مبلغ في حساب مصرفي، ولا يستخدمها في مشتريات تزيد على قيمة المبلغ المودع.

1. **الإصدار والاستخدام:** تصدر لمن له رصيد، وتوفر السحب النقدي أو تسديد الأثمان بقدر الرصيد ويُخصم فورًا.
2. **الرسوم:** لا يتحمل العميل رسومًا إلا في السحب النقدي أو شراء عملة أخرى، وتصدر برسم مالي أو بدونه.

الفرق عن غير المغطاة: لا تمثل مديونية؛ لأن العميل يدفع من رصيده، وتختلف عن غير المغطاة التي تقوم على الائتمان الممنوح للعميل؛ إذ يقترضه البنك ثم يرجع عليه.

حكمها: أجاز العلماء المعاصرون التعامل بها إذا لم يتضمن العقد شرط دفع الفائدة عند التأخر في السداد؛ لأن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يحصل شرط يترتب عليه فائدة ربوية.

قرار المجمع الفقهي الدولي رقم ١٣٩ (١٥٥): المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م بجواز إصدار البطاقات المغطاة والتعامل بها إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر، وينطبق عليها القرار ١٠٨ (١٢٢) بشأن الرسوم والخصم على التجار والسحب النقدي، ويجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بها.

2 القسم الثاني: البطاقات غير المغطاة:

تعريفها: عرّفها المجمع الفقهي بأنها: مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناءً على عقد بينهما، يمكنه من شراء السلع أو الخدمات دون دفع الثمن حالًا، لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة، وبعضها لا يفرض، وتتنوع تبعًا لأسلوب تسديد دينها إلى نوعين.

١ البطاقة المحددة (الدفع الشهري):

تعريفها: يُطالب حاملها بتسديد المبالغ دفعة واحدة بدون زيادة بعد فترة سماح تتراوح بين ثلاثين وستين يومًا.

1. **الائتمان والتسديد:** أداة ائتمان في حدود مبلغ معين، ويلزم حاملها بالتسديد خلال مدة السماح.
2. **المدفوعات وعدم السداد:** يلزم حاملها بمدفوعات أربعة: رسم الاشتراك والتجديد وفوائد الإقراض والتأخر، وفي حال عدم السداد يُطالب قضائيًّا وتلغى عضويته.

حكمها: يحرم التعامل بها؛ لتضمنها شرط زيادة ربوية على أصل الدين، ويجوز قبولها وإصدارها إذا لم يشترط فائدة ربوية عند التأخر، وبشرط ألا يتعامل بها فيما حرمته الشريعة.

٢ البطاقة المتجددة:

تعريفها: لها خصائص النوع الأول إلا أن الدين قابل للتجديد؛ فعند السحب النقدي تجري الفوائد الربوية بمجرد السحب، وعند الشراء يُخير العميل بين السداد كاملًا في فترة السماح أو

دفع جزء ثم يعود بفائدة مركبة.

1. **الرسوم والقرض:** البنوك تتقاضى رسومًا على الإصدار والتجديد، ويقدم لحاملها قرض بنكي.
2. **المديونية:** لا يوجد حد أعلى للمديونية.

حكمها: لا خلاف بين العلماء المعاصرين على تحريم التعامل بها؛ لاشتمالها على عقد إقراض ربوي، إذ يتضمن عقدها زيادة الدين بزيادة الأجل، فالعلاقة بين المصدر والحامل علاقة مقرض بمقترض.

- **الإجماع على التحريم:** لا خلاف بين العلماء المعاصرين على تحريمها؛ لاشتمالها على عقد إقراض ربوي.
- **زيادة الدين بزيادة الأجل:** إذ يتضمن عقدها زيادة الدين بزيادة الأجل، فالعلاقة بين المصدر والحامل علاقة مقرض بمقترض.

معيار هيئة المحاسبة والمراجعة ٢٠٠٠م: لا يجوز للمؤسسات المالية الإسلامية إصدارها؛ كون الدين يسدد بفوائد ربوية، ويجوز إصدار بطاقة لدين يتجدد بشرطين: ألا يشترط فوائد ربوية عند التأخر، وأن تشترط المؤسسة عدم التعامل بها فيما حرمته الشريعة.

قرار مجمع الفقه الإسلامي بالرياض ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م: لا يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية ولو كان طالبها عازمًا على السداد ضمن فترة السماح؛ ويجوز إصدارها إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية، ويتفرع على ذلك: جواز أخذ رسوم مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرًا فعليًّا على الخدمات، وجواز أخذ البنك من التاجر عمولة على مشتريات العميل شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد، والسحب النقدي اقتراض من المصدر ولا حرج فيه إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا تعد الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته من قبيلها، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا.

المسألة الثانية: أثر الشروط الباطلة على صحة عقد البطاقة:

البيان وسبب الخلاف: عقد البطاقة غير المغطاة "المتجددة خاصة" يتضمن شرطًا فاسدًا، وهو: زيادة على الدين عند التأخر في السداد، وإذا كان العميل واثقًا من نفسه أنه سيوفي في

مدة السماح، فلا يكون هناك تأخير أصلًا، فهل يصح منه الدخول في هذا العقد مع علمه باشتراط الزيادة فيه؟ هذه هي المسألة، والسبب في اختلاف العلماء فيها راجع إلى قاعدة سابقة: هل عقد الربا عقد باطل لا يمكن تصحيحه ولا إقراره بحال، أم هو عقد فاسد يمكن تصحيحه بإسقاط الشرط الفاسد منه؟ فمن قال إنه باطل حرم التعامل؛ لأن الشرط الفاسد لا يمكن تجاوزه، ومن قال إنه فاسد أجاز، لأن الشرط المذكور يمكن إسقاطه عمليًّا إذا التزم العميل بالسداد في مدة السماح.

الرأي:	البيان:
الأول:	**الجواز** ، ومن أظهر من قال به د. محمد تقي العثماني.
الثاني:	**عدم الجواز** ، وإلى هذا القول ذهب د. علي السالوس.

أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة من السنة والقياس والمعقول.

من السنة: حديث قصة بريرة: حديث عائشة: قال ﷺ: «خذيها، فأعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق» ، ثم قال ﷺ: «أما بعد، ما بال رجال منكم يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله، وإن كان مائة شرط، فقضاء الله أحق، وشرط الله أوثق» ، ووجه الدلالة: جواز إجراء العقد بعد تصحيح الشرط الفاسد، ما دام حامل البطاقة يصححه بإسقاط الشرط ودفع الدين في تاريخه.

من القياس: قياس على غرامات المرافق: قياس إجراء العقد على ما عمت به البلوى من غرامات عقود الكهرباء والهاتف، وقد قرر د. محمد تقي العثماني أن المعاملة في أصلها ليست ربوية، فبمجرد شرط الغرامة لا يقال إنها محرمة، فإذا كان العزم على السداد في المدة حل الدخول.

من المعقول: العقد ليس باطلًا وإنما فاسد، وإنما مُنع من أجل وصف الربا، فعلى هذا يسقط الربا ويصح العقد؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

المناقشات الواردة على أدلة القول الأول: نوقشت أدلة القول الأول بما يلي.

⚠ **مناقشة دليل السنة:** بأن التصحيح إنما يكون بإسقاط المشترط لا المشروط عليه، ولأن الشرط في البطاقة ملزم لا يستطيع حامله التخلي عنه؛ وأجيب بأن المتعامل يمكنه إسقاطه إذا وثق من السداد في فترة السماح.

⚠ **مناقشة القياس:** بأنه قياس مع الفارق؛ لشدة الحاجة إلى المرافق، أما البطاقات فالأمر فيها أدنى.

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي من المعقول: أن عقود البطاقات تؤول إلى المعاوضة؛ فإن فيها قرضًا أو وعدًا بالقرض، والقرض وإن كان تبرعًا في الابتداء فهو معاوضة في الانتهاء.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو القول الأول** ، القائل بجواز إجراء العقد لمن غلب على ظنه الوفاء في مدة السماح، مع إسقاط الشرط الفاسد.

✓ **انتفاء الحرج:** لانتفاء الحرج عمن غلب على ظنه القدرة على الوفاء في مدة السماح.

✓ **إبطال الشرط الفاسد:** مع إبطال الشرط الفاسد باتخاذ الاحتياطات اللازمة.

⚠ **تنبيه على جهة المشترط:** وأما من جهة المشترط فاشتراطه فوائد التأخير حرام باتفاق، وهو من ربا الجاهلية، وهو ما يسمى قاعدة «زدني أنظرك».

5 أطراف بطاقات الائتمان:

البيان: التعامل بالبطاقة الائتمانية ليس علاقة بين طرفين فقط، بل بين أربعة أطراف، وكل علاقة من هذه العلاقات بين كل اثنين منها لها حكمها الخاص، ومن هنا كان لا بد من تحديد كل طرف بدقة قبل الدخول في التكييف الفقهي.

1 **البنك المصدر:** هو الجهة المالية التي أصدرت البطاقة، ويلتزم بسداد قيمة مشتريات الحامل للتاجر، ثم يرجع على الحامل، ويصدر البطاقة بناءً على ترخيص معتمد من المنظمة العالمية.

2 **حامل البطاقة:** هو العميل الذي صدرت البطاقة باسمه، ويلتزم للمصدر بالوفاء بكل ما أنفقه بواسطتها، وهو المشتري الفعلي للسلعة أو الخدمة.

3. **التاجر:** هو البائع أو مقدم الخدمة الذي يقبل البطاقة، ويطالب المصدر بقيمة ما باعه، وكل المؤسسات والشركات التي تقدم الخدمات وتقبل عمليات البيع.

4. **المنظمة العالمية:** هي المالكة للعلامة التجارية كفيزا وماستركارد وأمريكان إكسبريس، ترخّص للبنوك بإصدار البطاقات، وتشرف على قواعد استخدامها.

المسألة الثالثة: التكييف الفقهي للعلاقة بين المصدر والحامل:

البيان وسبب الخلاف: المصدر هنا هو البنك الذي أصدر البطاقة، والحامل هو العميل الذي صُرفت له، والعلاقة بينهما هي: البنك سلّمه البطاقة، فيشتري بها من التجار، والبنك يدفع عن التاجر، ثم يرجع على الحامل ليستوفي منه ما دفع، فما نوع هذا العقد في الفقه الإسلامي؟ هذا هو محل النزاع، والسبب في اختلاف العلماء ثلاثة أمور: الأول: أن بعضهم لم يقف على حقيقة النظام الذي تقوم عليه البطاقة، فتحدث عن عقد لا يطابق الواقع، الثاني: أن بعضهم لم يدقق في العقود المبرمة بين الأطراف، فبنا حكمه على غير ما هو موجود، الثالث: أن العلاقة بين الأطراف معقدة، فتتداخل فيها عدة عقود، فيصعب إدخالها تحت عقد واحد، ومن هنا تعددت الأقوال إلى سبعة، كلٌّ ينظر للعلاقة من زاوية معينة.

الرأي:	البيان:
الأول:	**علاقة ضمان** ، ومن أبرز القائلين به د. نزيه كمال حماد.
الثاني:	**علاقة حوالة** ، ويُعزى هذا القول إلى د. وهبة الزحيلي.
الثالث:	**كفالة قبل الاستخدام ثم حوالة بعده** ، واختاره د. عبد الستار أبو غدة.
الرابع:	**وكالة** ، ومن نُسب إليه هذا القول الشيخ علي عندليب.
الخامس:	**وكالة وحوالة وكفالة وقرض حسن** ، قال به فريق من المعاصرين.
السادس:	**علاقة إقراض؛ قرض ربوي بفوائد معجلة ومؤجلة** ، وعليه د. بكر أبو زيد.
السابع:	**معاملة مستجدة تندرج تحت العقود غير المسماة** ، وقال به د. أسامة الأشقر.

وجه كل قول ومناقشته: نستعرض فيما يلي وجه كل قول والمناقشات الواردة عليه.

1. **الضمان:** وجهه أن المصدر ضمن حامل البطاقة في سداد ما عليه للتاجر، وهذا ضمان الحق قبل وجوبه وهو جائز عند الجمهور؛ لأن الضمان من التبرع، والتبرع يصح مع الجهالة، ويناقش بوجهين: أن الضمان تبرع محض والجهة المصدرة تهدف للربح، وأن الدائن في هذه المعاملة لا يستطيع مطالبة المضمون عنه وإنما يطالب الضامن، وأجيب: بأن الحنفية والمالكية أجازوا اشتراط براءة ذمة المضمون عنه؛ استدلالًا بحديث أبي أمامة: «الزعيم غارم» — ووجهه أن النبي ﷺ خص الضامن بالغرم فاقتضى براءة المضمون عنه — وبحديث أبي سعيد في الذي عليه ديناران حين قال علي: «هما عليَّ يا رسول الله، وأنا لهما ضامن»، فقال ﷺ: «جزاك الله خيرًا، فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك» ، وقال: «بل للمسلمين عامة» .

2. **الحوالة:** وجهه أن حامل البطاقة محيل، والتاجر محال، والمصدر محال عليه، ويناقش بوجهين: أن العقد ليس فيه ما يشير للحوالة، وأنه لا دين للمحيل على المحال عليه، وأجيب: بأن الحوالة لا يشترط فيها أن يكون المحيل مدينًا عند الحنفية؛ استدلالًا بحديث أبي هريرة: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» ؛ ويلاحظ تعارضه مع أخذ المصدر أجرًا على الخدمات.

3. **الكفالة ثم الحوالة:** واختاره د. عبد الستار أبو غدة؛ ويناقش بأن الكفالة لا تكون إلا بدين ثابت، وقبل الاستخدام لم يثبت دين.

4. **الوكالة:** ومن نُسب إليه هذا القول الشيخ علي عندليب؛ ويناقش بأن العلاقة في الوكالة بين طرفين، وفي البطاقة بين ثلاثة، وبأنه يجوز في الوكالة مطالبة الموكل والوكيل، وفي البطاقة يطالب الوكيل فقط.

5. **الوكالة والحوالة والكفالة والقرض:** قال به فريق من المعاصرين؛ ويناقش بأن تسليم الوكالة والضمان لا يلزم منه تسليم الحوالة.

6. **الإقراض:** وعليه د. بكر أبو زيد؛ ويناقش بأن حقيقة القرض دفع مال يُرد بدله وعقد الائتمان قد يوجد ولا يوجد القرض، وبأنه يقتضي ألا يكون المصدر مسؤولًا عن البضاعة المعيبة، وبأن القرض من عقود الإرفاق والبنوك تهدف للربح.

المعاملة المستجدة: وقال به د. أسامة الأشقر؛ ووجهه أن العقد جديد لا يندرج في صورته الكلية تحت عقد واحد.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو القول السابع** ، القائل بأن العلاقة بين المصدر والحامل معاملة مستجدة تندرج تحت العقود غير المسماة.

- **الأصل في العقود المشروعية:** لأن العقود الأصل فيها المشروعية إن لم يوجد فيها مخالفات شرعية.
- **العقود الجديدة:** والعقود الجديدة مشروعة ما لم تعترها مخالفات.
- **قراءة نقدية للتكييفات:** وقد قرر د. أسامة الأشقر أن التكييفات لم تسر على منهج واحد ولم تنتج حكمًا واضحًا، وأن كلًّا منها ضاق عن هذا النوع، والسبب أن الذين صنعوا البطاقات لم يقيموها على هذه العقود، فالتكييف تصوري لا حقيقي، والطريقة المرضية النظر إليها كعقد جديد مستحدث مشروع إن لم يوجد فيه مخالفات.

المسألة الرابعة: التكييف الفقهي للعلاقة بين المصدر والتاجر:

البيان وسبب الخلاف: التاجر هو البائع الذي يقبل البطاقة من العميل ويبيع له، ثم يطالب البنك المصدر بقيمة المبيعات، والبنك المصدر يدفع له بعد خصم نسبة معينة، فما نوع العلاقة بين التاجر والبنك؟ والسبب في اختلاف العلماء فيها: أن التاجر لا يطالب العميل المشتري وإنما يطالب المصدر مباشرة، ثم إن المصدر يخصم نسبة من قيمة الفاتورة، فهل هذه النسبة أجر على خدمة يؤديها المصدر للتاجر؟ أم هي مقابل ضمانه للدين؟ أم غير ذلك؟ ومن هنا تعددت التكييفات.

الرأي:	البيان:
الأول:	**كفالة مقترنة بالحوالة** ؛ ووجهه استمرار التزام المصدر دون الرجوع على المحيل عند الإفلاس.
الثاني:	**وكالة بأجر** ؛ بأن المصدر وكيل للتاجر في قبض استحقاقات المبيعات، وأجيب عن دعوى أنه من «ضع وتعجل» بأن التسديد فوري عند تسليم سندات البيع.
الثالث:	**حوالة** ؛ فالبنك محال عليه والتاجر محال والحامل محيل؛ ويناقش بأن أخذ العوض على الحوالة لا يجوز مطلقًا.
الرابع:	**سمسرة** ، ومن أشهر من قرره د. رفيق المصري، وبه أخذت هيئة المحاسبة والمراجعة؛ ووجهه أن المصدر يرسل حاملي البطاقات إلى التاجر ويتقاضى أجرًا عن مشترياتهم، ويوفر خدمات كتحصيل الفواتير والإيداع المباشر.

الخامس:	كفالة ووكالة .
السادس:	علاقة مستجدة الأصل فيها الإباحة ، وذهب إليه د. أسامة الأشقر.

الراجح: الراجح والله أعلم هو القول السادس ، القائل بأن العلاقة بين المصدر والتاجر علاقة مستجدة الأصل فيها الإباحة؛ اطرادًا لما رجحناه في العلاقة بين المصدر والحامل، ولأن العقود الأصل فيها المشروعية ما لم تعترها مخالفات.

المسألة الخامسة: التكييف الفقهي للعلاقة بين الحامل والتاجر:

البيان وسبب الخلاف: الحامل هو المشتري، والتاجر هو البائع الذي يقبل البطاقة، والعلاقة بينهما هي علاقة الشراء الفعلية، فإذا ذهب العميل إلى متجر واشترى سلعة بالبطاقة، فما نوع العقد الذي وقع بينه وبين التاجر؟ هذا محل النزاع، والسبب في الخلاف: أن الثمن لا يدفعه الحامل للتاجر مباشرة، بل يدفعه المصدر، فيحتمل أن تكون العلاقة بيعًا أو إجارة بحسب المبيع، ويحتمل أن تكون من نوع خصم الأوراق التجارية؛ لأن الفاتورة التي يوقعها الحامل تشبه الكمبيالة، يخصمها التاجر لدى المصدر مقابل نسبة.

الرأي:	البيان:
الأول:	لا تخرج عن بيع أو إجارة ؛ فإن كان تمليكًا فهو بيع، وإن كان تقديم خدمات معلومة فهو إجارة، ويحيل الحامل التاجر على المصدر لاستيفاء الثمن أو الأجرة.
الثاني:	علاقة شبيهة بخصم الأوراق التجارية ؛ بأن الفاتورة الموقعة بمثابة كمبيالة مستحقة يخصمها التاجر لدى المصدر مقابل نسبة.

الراجح: الراجح والله أعلم هو الأول ، القائل بأن العلاقة لا تخرج عن بيع أو إجارة.

- التكييف حسب المضمون: فإن كان تمليكًا فهو بيع، وإن كان تقديم خدمات فهو إجارة.
- شرط الصحة: ويشترط اكتمال الشروط وانتفاء الموانع.

6 العلاقة بين المنظمة الراعية وأطراف البطاقة:

مصادر دخلها: تغطي المنظمة مصاريفها من إيرادات الاشتراك والعضوية والإيرادات ربع السنوية وثمن البرامج والرسوم.

التخريج: علاقة سمسرة، وممن اختاره د. عبد الستار أبو غدة؛ لأنها صاحبة الحق المعنوي وتزود البنوك بالخبرة الفنية والإدارية.

المسألة السادسة: حكم رسوم الإصدار والتجديد:

البيان وسبب الخلاف: المصدر — وهو البنك — يتقاضى من الحامل — وهو العميل — رسومًا عند إصدار البطاقة أول مرة، وعند تجديد صلاحيتها، وعند استبدالها إن ضاعت أو تلفت، فما حكم هذه الرسوم؟ والسبب في اختلاف العلماء فيها: أن المصدر يقدم للحامل خدمتين متلازمتين: خدمة إصدار البطاقة وإدارتها، وخدمة ضمان الدين للتاجر، فمن نظر إلى أن أهم ما يقدمه المصدر هو الضمان، وأن الضمان شبيه بالقرض، رأى أن أخذ الأجر عليه داخل في الربا، ومن نظر إلى أن الرسوم في مقابل ما يبذله المصدر من خدمات فعلية كإصدار البطاقة وإدارتها وإرسال الكشوف وتشغيل الأجهزة، أجازها، ومن هنا تعددت الأقوال، ونذكر أولًا أنواع الشروط في العقد تمهيدًا لبيان الحكم.

نوع الشرط:	البيان:
الصحيحة:	كاشتراط فتح حساب.
الباطلة:	فرض نسبة عقوبة على تأخير السداد أو على تجاوز المبلغ المسموح أو على تحويل العملات أو على العمليات النقدية.
المختلف فيها:	رسوم الإصدار والتجديد والاستبدال والمدفوعات المأخوذة من التاجر.

1. **رسوم العضوية والتجديد:** رسوم العضوية تُحصل مرة واحدة، ورسوم التجديد تُحصل عند تجديد صلاحية البطاقة.
2. **رسوم الاستبدال والسحب:** رسوم الاستبدال تُحصل عند ضياع البطاقة أو تلفها، ورسوم السحب النقدي تُحصل عند السحب.

الرأي:	البيان:
الأول:	**التحريم** ، وإلى التحريم مال د. علي السالوس.
الثاني:	**الجواز** ، ومن القائلين بالجواز د. عبد الستار أبو غدة، وصدر به قرار مجمع الفقه الدولي وهيئة المحاسبة والمراجعة والهيئة الشرعية للراجحي وبيت التمويل الكويتي وندوة البركة الثانية عشرة.
الثالث:	**التفصيل** ؛ فمنها محرمة كرسوم الضمان، ومنها غير محرمة كأجور الخدمات المقدمة؛ للقاعدة: «التابع تابع».

- **دليل التحريم ومناقشته:** دليله من المعقول: أن الضمان شبيه بالقرض فما يأخذه من رسوم فيه شبهة الربا؛ لكونه من المنفعة المشروطة في القرض، فيحرم سدًّا للذريعة، ويناقش: بأنه لا علاقة بين القرض والرسوم؛ فهي تفرض ولو لم تستخدم البطاقة، وبأن سد الذريعة لا يجوز التوسع فيه لدرجة الحرج، ويمكن تسليم تحريم الزيادة دون تحريم كل رسم؛ لأن قيمة الخدمات يصعب تحديدها بدقة والغرر اليسير معفو عنه.
- **دليل الجواز ومناقشته:** دليله من القياس: قياس أخذ رسوم البطاقة على الرسوم المتعارف عليها في المرافق العامة؛ إذ المقصود تغطية نفقات الأعمال الإدارية، ومن المعقول: أن الرسوم مقابل خدمات، فرسم الاشتراك أجر مقطوع لأصل الخدمة المصرفية، فهي وكالة بأجر على عمل يؤديه المصدر، ويناقش: بأن مجموع الرسوم قد يزيد كثيرًا على التكاليف؛ فيشترط أن تكون في مقابل التكلفة الفعلية خروجًا من شبهة الأجر على الضمان والمنفعة المشروطة في القرض.
- **دليل التفصيل:** من المعقول: أن الرسوم إن كانت واردة على التكاليف الفعلية فهي جائزة، أما رسوم الضمان فيحرم أخذ الأجر عليها، وكذا أجور الخدمات التابعة للضمان؛ للقاعدة: «التابع تابع».

الراجح: **الراجح والله أعلم هو القول الثاني** ، القائل بجواز أخذ رسوم الإصدار والتجديد، مقيدًا بشرطين: أن يكون المبلغ ثابتًا لا نسبة مئوية، وأن يكون مقابل خدمة فعلية حقيقية.

- **مقابل خدمات فعلية:** لأنها مقابل خدمات فعلية.
- **رفع الحرج:** رفعًا للحرج عن جميع الأطراف، وضمانًا لاستمرارية الخدمات.
- **توسط بين القولين:** وهو توسط بين تحريم الأول وإطلاق الثاني.

- **شرطان للجواز:** مقيدًا بشرطين: أن يكون المبلغ ثابتًا لا نسبة مئوية، وأن يكون مقابل خدمة فعلية حقيقية.

قرارات الجهات: ندوة البركة الثانية عشرة: بجواز أخذ رسوم العضوية والاشتراك والتجديد والاستبدال على أن تكون مقابل الخدمات المقدمة، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة في القرار رقم (١) بعمان ١٤٠٧هـ/١٩٨٦م: «جواز أخذ أجور عن خدمات القروض، على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعًا».

المسألة السابعة: عمولات المنظمة الراعية:

البيان وسبب الخلاف: المنظمة الراعية هي الجهة المالكة للعلامة التجارية، مثل: فيزا وماستركارد، وهي لا تتعامل مع حاملي البطاقات مباشرة، وإنما تتعامل مع البنوك المصدرة، فتأخذ منها رسومًا على الترخيص باستخدام العلامة التجارية، وعلى الخدمات الفنية والإدارية والبرامج التي تقدمها، فما حكم ما تأخذه المنظمة من هذه البنوك؟ والسبب في اختلاف العلماء: أن المنظمة ليست طرفًا مباشرًا في المعاملة الربوية، وإنما هي وسيط تقني يقدم خدمة، لكنها في الوقت نفسه تيسّر عمل البطاقات الربوية وتستفيد منها، فمن نظر إلى كونها وسيطًا تقنيًّا محضًا أجاز، ومن نظر إلى أنها تشارك في تيسير الربا تفصيلًا بحسب نوع البطاقة.

الرأي:	البيان:
الأول:	**مشروعية العمولة** ؛ لأنها في حدود الخدمة، والمنظمات ليست شركات هدفها الربح بل كالنادي أو الهيئة المالية.
الثاني:	**التفصيل** ؛ فإن كانت البطاقات ربوية تعتمد الفائدة فعملها محرم لتيسيره الإقراض بالفائدة، وإن لم يترتب على وساطتها فوائد ربوية فأجرتها صحيحة.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو القول الثاني** ، القائل بالتفصيل بين البطاقات الربوية وغيرها.

- **قاعدة التبعية:** الوساطة تأخذ حكم ما توسطت فيه؛ فوساطتها في الحرام حرام، وفي الحلال حلال.
- **الأصل في الوساطة الإباحة:** فلا يخرجها عن الأصل إلا اشتمالها على محذور شرعي.

المسألة الثامنة: العمولات التي يقتطعها المصدر من التاجر:

البيان وسبب الخلاف: التاجر هو البائع الذي يقبل البطاقة، والمصدر هو البنك، والتاجر لا يقبض الثمن من العميل، وإنما يطالب المصدر فيسدد له، لكن المصدر لا يدفع له المبلغ كاملًا، بل يخصم منه نسبة تتراوح بين ٢ و٥٪ من قيمة الفاتورة، كما في المثال: إذا كانت المشتريات بمائة جنيه، فإن التاجر يستوفي من البنك خمسة وتسعين جنيهًا، ويبقى خمسة جنيهات عند البنك عمولة، فما حكم هذه العمولة؟ والسبب في اختلاف العلماء: أن هذه النسبة قد يراها بعضهم مقابل خدمات فعلية يقدمها البنك للتاجر — كتحصيل قيمة الفواتير، والإيداع المباشر، والترويج للمتجر، وجذب العملاء — فيجيزها، بينما يراها آخرون في مقابل ضمان الدين، فيدخلها في قرض جر نفعًا، لأن البنك ضمن الدين للتاجر وأخذ عليه زيادة، وهذان النظران هما أساس الخلاف.

الرأي:	البيان:
الأول:	**الجواز** ، وقال به د. عبد الستار أبو غدة.
الثاني:	**عدم الجواز** ، ومن المانعين الشيخ علي عندليب.

أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بثلاثة أوجه من المعقول.

1. **أجرة السمسرة:** أنها أجرة السمسرة التي يقوم بها البنك للتجار لحاملي البطاقات، ومقابل الأجهزة والنشرات؛ ويناقش بأن السمسار يقوم ببيع أشياء معروفة والمصدر قد لا يعلم بها.
2. **المصالحة على الدين:** أنها من باب المصالحة على الدين بناءً على قول الحنفية بجواز رجوع الضامن على المكفول بما ضمن؛ ويناقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن البنوك تلتزم بالدفع قبل معرفة المال وقبل الأجل فتكون مقرضة ثم تأخذ من العميل مقابل الزيادة.
3. **أجر الوكالة والوساطة:** أنها أجر على وكالة ووساطة بين التاجر والحامل من ترويج ودعاية وتأمين زبائن وتسهيل تحصيل.

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بوجهين من المعقول.

1. **قرض جر نفعًا:** أن البنك إذا سدد للتاجر حالًا ثم رجع على المصدر مع خصم عمولته وعمولة المصدر فقد أقرض التاجر بالفائدة؛ فتصير قرضًا جر نفعًا؛ ويناقش بأن المصدر يأخذ نسبة أجرًا على قبول ضمان الدين، فلا إقراض للتاجر بل للعميل.

2. **شبهة خصم الأوراق:** أن نسبة الخصم تشبه خصم الأوراق التجارية وهو محرم.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو القول الأول** ، القائل بجواز العمولة التي يحصلها البنك من التاجر.

- **دفع الحرج:** دفعًا للحرج؛ فالحرج مرفوع بنصوص الشريعة.
- **مقابل خدمات:** لأن النسبة مقابل خدمات كتحصيل الفواتير وجذب العملاء.
- **الإنفاق اللازم:** ولأن الدعاية والترويج وتحصيل القيم يحتاج إلى إنفاق.
- **حقيقة عمل البنك:** ولأن حقيقة عمل البنك الوكالة في تحصيل الدين، والوكالة بأجر جائزة.

قرارات الجهات: الهيئة الشرعية للراجحي: لا نرى مانعًا من الحصول على نسبة من قيمة ما يشتريه حامل البطاقة ما دامت تستقطع من ثمن خدمة أو سلعة، وعدت هيئة بيت التمويل الكويتي والبنك الإسلامي الأردني العمولة أجر وكالة على الوساطة والترويج وتحصيل الديون، والمجمع الفقهي: يجوز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

المسألة التاسعة: عمولة السحب النقدي:

البيان وسبب الخلاف: السحب النقدي معناه: أن يسحب حامل البطاقة نقودًا من البنك المصدر عن طريق مكائن الصرف الآلي، فيقرضه البنك مبلغًا، ويخصم من حسابه عند السداد مبلغًا زائدًا عمولة، كأن يسحب ألف جنيه، فيُخصم منه ألف وعشرة، فالعشرة زيادة على السحب، فما حكم هذه الزيادة؟ والسبب في اختلاف العلماء: أن السحب النقدي في حقيقته اقتراض؛ فالبنك يدفع للعميل نقدًا، ثم يستوفي منه لاحقًا، والزيادة على القرض في الجملة ربا، لكن هذه الزيادة قد يُنظر إليها من جهة أخرى؛ فهي تقابل خدمات فعلية: أجهزة الصرف، وصيانتها، وشبكات الاتصال، وما يتحمله البنك من مصاريف تشغيلية، فمن غلّب جانب القرض،

حرم الزيادة كلها أو قيدها بقدر النفقات الفعلية، ومن غلّب جانب الخدمة، أجازها ضمن قيود، وهنا فرق أيضًا بين السحب اليدوي والسحب الآلي.

1. **السحب اليدوي:** بإبراز البطاقة لموظف البنك، وفي هذه الحالة لا يجوز أخذ رسوم لأنها ربا ولا يقابلها تكاليف فعلية، وأكدت فتاوى الهيئات الشرعية حرمة استخدام البطاقة في السحب اليدوي من البنوك الربوية لأنها تحتسب فائدة ربوية.
2. **السحب الآلي:** وله تكاليف من أجهزة وصيانة واستئجار مواقع.

الرأي:	البيان:
الأول:	**عدم الجواز** ، وذهب إلى عدم الجواز د. عبد الستار أبو غدة؛ ودليله أن السحب قرض والزيادة على القرض ربا، ويناقش: بأنه ليس كل زيادة ربا؛ فقد تكون تكلفة، والمنفعة المحرمة هي الزائدة المشروطة للمقرض.
الثاني:	**الجواز** ، وللقائلين به ثلاث اتجاهات: أولها الجواز مطلقًا نسبة أو مبلغًا مقطوعًا، ودليله أنها أجر على الخدمة المصرفية، ويناقش بأن الحامل قد يستخدمها في الاستعلام عن الرصيد فهي كالسحب من حيث التكلفة؛ وثانيها الجواز بشرط أن تكون مبلغًا مقطوعًا لا نسبة في مقابل النفقات الفعلية، وهو قول كثير من المعاصرين وصدر عن هيئة بيت التمويل الكويتي، ويناقش بأن العقد مركب من قرض وإجارة ولا يجوز الجمع بينهما؛ وثالثها الجواز بشرط وجود تغطية في الحساب لوقوع المقاصة فورًا، ودليله أنها أجرة على توصيل النقود.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الاتجاه الثالث** من اتجاهات القول الثاني، القائل بجواز أخذ الرسوم بشرط وجود تغطية في الحساب لوقوع المقاصة فورًا.

- **الاحتياط من الربا:** لما فيه من الاحتياط والحذر من أكل الربا.
- **تأييد المجمع:** ويؤكده قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ١٣ (٣/١) في دورته الثالثة بعمان ١٩٨٦م: يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض في حدود النفقات الفعلية، وكل زيادة محرمة.

ملاحظة: رأت بعض الهيئات وضع صندوق خاص لهذه الفوائد المحتسبة والتخلص منها في وجوه الخير، كما قرر الشيخ مصطفى الزرقا أن البنك الإسلامي يشترط إنشاء صندوق خاص لتلك

الفوائد التي تأتيه رغمًا عنه، يوجه إلى جهات الخير، شأن سائر الفوائد التي تحتسب لبعض المودعين.

المسألة العاشرة: شراء الذهب والفضة ببطاقة الائتمان:

البيان وسبب الخلاف: صورة المسألة: أن يذهب حامل البطاقة إلى محل الحلي، فيشتري ذهبًا أو فضة، ثم يقدم البطاقة بدلًا من النقود، فيتأكد البائع من صلاحيتها، ويوقّع الحامل على السند، ويبعث البائع نسخة للمصدر ليتحصل على قيمة السند بعد فترة، فما حكم هذا الشراء؟ والسبب في اختلاف العلماء يرجع إلى شرط من شروط صحة بيع الذهب والفضة، وهو: التقابض في مجلس العقد، فبعضهم يرى أن مجرد تسلم البائع لقسيمة الدفع الموقعة من الحامل قبض حكمي كافٍ، فيكون التقابض متحققًا، ويصح البيع، وبعضهم يرى أن القبض الفعلي إنما يقع حين يدفع البنك للتاجر بعد فترة، فيكون البيع مؤجلًا من أحد الطرفين، وهذا لا يجوز في بيع النقدين، ومن هنا تعددت الأقوال.

شروط صحة بيع النقد بمثله: قبل بيان الحكم، لا بد من معرفة شروط صحة بيع النقد بمثله؛ لأن شراء الذهب والفضة بالبطاقة تطبيق عليها، وقد اشترط الجمهور التماثل إذا اتحد الجنس، والتقابض في مجلس العقد.

حديث عبادة بن الصامت: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» ، فقوله «يدًا بيد» دليل على اشتراط التقابض.

حديث البراء بن عازب: عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقًا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج، فجاءني فأخبرني، فقلت: هذا أمر لا يصلح، قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك على أحد، فأتيت البراء بن عازب فسألته، فقال: «قدم النبي ﷺ ونحن نبيع هذا البيع، فقال: ما كان يدًا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا» .

حديث أبي سعيد الخدري: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز» .

الإجماع: قال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل التقابض فالصرف فاسد.

الرأي:	البيان:
الأول:	**الصحة مطلقًا، مغطاة أو لا** ، ومن أجازه د. عبد الستار أبو غدة، وبه صدرت فتوى هيئة الرقابة الشرعية ببيت التمويل الكويتي؛ لأن تسلم البائع القسيمة الموقعة قبض حكمي كقبض الشيك، ويناقش بأن الشيك أداة وفاء في الحال فقبضه قبض حكمي، وبطاقة الائتمان أداة وفاء في المستقبل، ودليله الآخر أن التاجر عند تمرير البطاقة يقرأ الشريط ويوصل المعلومات للحاسب فيقيد المبلغ ويحوله.
الثاني:	**عدم الصحة مطلقًا** ، ومن أخذ بالمنع الشيخ عبد الرحمن بن عقيل؛ ودليله حديث عبادة «الذهب بالذهب... يدًا بيد»، ووجه الدلالة أن التقابض الفوري شرط وكل تأخير مخالف، ويناقش بأن «يدًا بيد» لا يدل على اشتراط القبض باليد وإنما القبض الحكمي في المجلس، ومن المعقول أن شرط القبض غير متحقق، وأجيب بأن شرط التقابض لا يتحقق لأن الحامل يتسلم الذهب ويوقع القسيمة ولا يدفع الثمن، والذي يدفع هو المصدر بعد فترة.
الثالث:	**الصحة إذا كانت مغطاة** ، واختار الصحة في المغطاة د. وهبة الزحيلي، وهو ما قرره مجلس المجمع: «لا يجوز شراء الذهب والفضة، وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة»، ودليله أن الشراء بالمغطاة فيه تقابض حكمي معتبر إذا دفع المصدر المبلغ للتاجر بدون أجل على أنه وكيل للمشتري، ويرد بأن التفريق بين المغطاة وغيرها لا تأثير له في حقيقة القبض، فالبنك كفيل ووكيل بالدفع.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو القول الأول** ، القائل بجواز شراء الذهب والفضة ببطاقة الائتمان مطلقًا، مغطاة كانت أو غير مغطاة.

القبض الحكمي الصحيح: لأن القبض بالبطاقة قبض حكمي صحيح؛ إذ القبض إثبات اليد ويستند في كثير من أحكامه إلى العرف.

- **قبول البطاقة عند الناس:** ولأن البطاقة أصبح لها من القبول ما يفوق الأوراق النقدية والتجارية.

المسألة الحادية عشرة: البدائل الشرعية للبطاقة غير المغطاة:

البيان: البطاقة غير المغطاة فيها إشكال شرعي كما تبين، ولذلك اقترح العلماء المعاصرون بدائل شرعية تحقق المنفعة نفسها، لكنها بمعاملات مباحة، بعيدًا عن القرض بفائدة، والغرض من هذه البدائل ثلاثة أمور: اجتناب المحظور، وتنقية المعاملة من المحاذير الشرعية، وإيجاد حل بعيد عن التبعية الأجنبية، وقد تنوعت هذه البدائل بحسب طبيعة المعاملة التي تقوم عليها.

1. **بطاقة البيع بالتقسيط:** بأن ينشئ البنك الإسلامي متاجر للبيع بالتقسيط، ويستفيد من ربح البيع والفارق بين الحال والمقسط؛ ولا تصلح للحصول على النقود.
2. **بطاقة المرابحة للآمر بالشراء:** بأن يوكل البنك العميل بأن يشتري ويقبض عنه ويسدد، ثم يبيع عليه بزيادة؛ ولا تسهم في توفير خدمات كالمطاعم والفنادق حيث ينتفع العميل بالخدمة قبل السداد.
3. **بطاقة الخصم الشهري:** تصدرها المصارف الإسلامية على أن تُحدد قيمة المسحوبات بمقدار الراتب الشهري دون فائدة؛ فتقوم على الوكالة إذا كان حساب العميل يفي، أما إذا لم يفِ فيسدد المصرف على أساس القرض الحسن بضمان الراتب، وهذا مشروع ومندوب إليه.
4. **تجديد الدين عن طريق التورق المصرفي:** يأخذ العميل مبلغًا يسدد به مديونية البطاقة ويسدد للمصرف مديونية التورق، وفي حال التأخر يبيع البنك سلعة بثمن أكبر على العميل ثم يبيعها عنه لطرف آخر ويسدد القرض الأول ويجدول الثاني.

ملاحظة: وهذه البدائل لم تسلم من الخلل الشرعي ومن عدم القدرة على تلبية الاحتياجات في الواقع العملي، ويوجد الآن نموذجان: فيزا التمويل التي أصدرها بيت التمويل الكويتي، وفيزا الراجحي التي أصدرتها شركة الراجحي المصرفية للاستثمار.

MNARA 01105406478

الشرط الجزائي وشرعية غرامات التأخير:

١ التعريف والصور والشروط والأحوال
٢ التكييف الفقهي
٣ حكمه على التأخير في تنفيذ الأعمال
٤ حكمه على التأخير في سداد الديون

١ التعريف:

الشرط لغةً: إلزام الشيء والتزامه، وجمعه شروط، والشرط بالتحريك العلامة، وفي اصطلاح الأصوليين: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

الجزاء لغةً: المكافأة على الشيء، ويكون ثوابًا وعقابًا، ويستعمل في الخير والشر.

نوع الشرط:	البيان:
الذي يقتضيه العقد	صحيح يجب الوفاء به بلا خلاف، كاشتراط تسليم المعقود عليه أو رده بالعيب.
من مصلحة العقد	صحيح باتفاق الفقهاء، كاشتراط صفة مباحة في المعقود عليه.
فيه منفعة معلومة	مختلف فيه، ليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته ولا منافيًا له، فجمهور الفقهاء يرون عدم صحة العقد والشرط لأنه مفسد للعقد، ويرى آخرون صحة العقد مع الشرط.
الباطل	ما لا يقتضيه العقد بل هو أمر زائد عليه لا يلائمه، ولا ورد به نص، ولا جرى به عرف، ولا منفعة فيه لأحد.

الشرط الجزائي – اصطلاحًا: هو **من المصطلحات المعاصرة التي لم ترد عند الفقهاء القدامى** ، وأخذت قوانين البلاد العربية هذا التعبير عن القوانين الغربية وأدخلت عليه تعديلات **ويعرف بأنه: اتفاق سابق على تقدير التعويض الذي يستحقه الدائن في حالة عدم التنفيذ أو التأخير فيه** .

تعريف المجمع الفقهي: **اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه** .

2 الصور والشروط والأحوال التي لا ينفذ فيها:

1 **صوره التي ذكرها السنهوري:** شروط المقاولة المتضمنة إلزام المقاول بمبلغ عن كل يوم تأخير، ولائحة المصانع المتضمنة خصم مبالغ من أجرة العامل جزاءً على الإخلال، واشتراط حلول جميع أقساط الدين إذا تأخر المدين في دفع قسط منها.

2 **عوامل العمل به:** تطور أساليب التجارة، وصيرورة القيمة المالية للمشاريع كبيرة، واتساع دائرة التجارة بين أطراف متباعدة لا يعرف بعضهم بعضًا، وظهور عقود جديدة كالامتياز والاستصناع الحديثة والنقل الجوي والبحري والتوريد والمقاولات، وشيوع المماطلة بين الناس.

3 **شروط تطبيقه:** **ثبوت الضرر، وألا يكون فيه مبالغة، وارتكاب المدين خطأً أو غشًّا تسبب في ضرر، وإعذار المدين** .

⚠ **حالة عدم النفاذ الأولى:** إذا كان كثيرًا عرفًا بعيدًا عن مقتضى القواعد الشرعية، فيرجع في تقدير الضرر إلى أهل الخبرة مع مراعاة العدل ورفع الضرر، لحديث عبادة بن الصامت: «أن رسول الله ﷺ قضى أن لا ضرر ولا ضرار» .

⚠ **حالة عدم النفاذ الثانية:** إذا كان هناك عذر في الإخلال بالالتزام فيكون العذر الشرعي مسقطًا لوجوبه حتى يزول.

🏛 **قرار هيئة كبار العلماء:** **الشرط الجزائي شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعًا، فيكون العذر مسقطًا لوجوبه حتى يزول** ، وإذا كان كثيرًا عرفًا يراد به التهديد المالي وجب الرجوع إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من ضرر، ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة، عملًا بقوله تعالى: «وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» ، وقوله: «وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى» ، وبقوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» .

🏛 **البند السادس من قرار المجمع الفقهي:** **لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت المدين أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من**

المسألة الأولى: التكييف الفقهي للشرط الجزائي:

البيان وسبب الخلاف: التكييف معناه: تحديد نوع العقد الشرعي الذي تندرج تحته المعاملة، لمعرفة حكمها الشرعي، والشرط الجزائي مصطلح معاصر لم يعرفه الفقهاء القدامى بهذا الاسم، فمن ثم كان لا بد من البحث: **هل هو من العقود المسماة التي لها شبيه في الفقه فيخرج عليه، أم معاملة مستجدة ليست من العقود المسماة وليس لها شبيه؟** والسبب في هذا الخلاف: أن الشرط الجزائي له شبه ببعض العقود المعروفة كالعربون والرهن من جهة، لكنه يختلف عنها في بعض الأوصاف من جهة أخرى، فمن نظر إلى وجه الشبه أخرجه على ذلك العقد، ومن نظر إلى الفروق رآه عقدًا مستقلًا جديدًا. وعلى هذا التكييف يترتب الحكم الشرعي في المسألتين التاليتين.

الاتجاه:	البيان:
الأول:	**من العقود المسماة** ، وله تخريجان: شبيه بالعربون، وشبيه بالرهن.
الثاني:	**معاملة مستجدة** ، ليست من العقود المسماة.

تخريجات الاتجاه الأول ومناقشاتها: أخرج أصحاب هذا الاتجاه الشرط الجزائي على أحد عقدين، ونوقش كالتالي.

1. **التخريج الأول: شبيه بالعربون:** وجه الشبه: أن كليهما تقدير للتعويض — فالشرط الجزائي تقدير للتعويض عند الإخلال، والعربون تقدير له عند العدول — وأن كليهما يوجب على من أخل عقوبة مالية، ويناقش: بأنه **قياس مع الفارق** ؛ لأن العربون مقابل حق العدول، والشرط الجزائي تعويض عن ضرر وقع فعلًا، والعربون يدفع عند العدول ولو لم يترتب ضرر بخلاف الشرط الجزائي، والعربون لا يجوز تعديله من القاضي بخلاف الشرط الجزائي، كما أن القول بأنه عقوبة مالية لا يصح لأنه تقدير للتعويض لا عقوبة.

التخريج الثاني: شبيه بالرهن: وجه الشبه: أنهما يؤكدان موجب العقد ولا يستقلان عنه، وجاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء أنه من الشروط التي تحقق مصلحة العقد؛ إذ هو حافز لإكمال العقد في وقته، فكان شبيهًا باشتراط الرهن، ويناقش: بأن كونه من مصلحة العقد لا نزاع فيه، لكن تشبيهه بالرهن غير مسلم؛ لأن الرهن ليس فيه تعويض عن ضرر، والقياس مع الفارق من ثلاثة أوجه: أن الشرط الجزائي مرتبط بوقوع الضرر بخلاف الرهن، والرهن عين يستوفي منها الدين أو من ثمنها بينما الشرط الجزائي في الغالب مبلغ مقدر مسبقًا، والرهن عين معلومة مقبوضة قبل المماطلة بخلاف الشرط الجزائي.

الاتجاه الثاني: معاملة مستجدة: وجهه أن **الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة ولا يحرم منها إلا ما دل الشرع على تحريمه** ، قال ابن القيم: «الأصل في العقود والشروط الصحة، إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه»، وقال: «فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر، والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم».

الراجح: **الراجح والله أعلم أنه معاملة مستجدة** ؛ لأن ما بينه وبين بعض العقود من وجه شبه إنما هي أوجه ظاهرية لا يمكن تكييفه عليها، ولأنه من المعاملات والأصل فيها الإباحة، فيباح التعامل به لأنه من مصلحة العقد.

عدم صحة التخريج على القديم: لأن ما بينه وبين العقود القديمة من شبه إنما هي أوجه ظاهرية لا تصح التكييف عليها.

الأصل في المعاملات الإباحة: فلا يخرج عنها إلا بدليل يقتضي التحريم.

من مصلحة العقد: إذ هو حافز لإكماله في وقته المحدد.

سد ذريعة الفوضى: وفي تصحيحه سد لأبواب الفوضى والتلاعب بحقوق العباد، وسبب من أسباب الحث على الوفاء بالعهود، تحقيقًا لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» .

المسألة الثانية: حكمه في حالة التأخير في تنفيذ الأعمال:

صوره في الأعمال: من أهم صوره: عقد الاستصناع، وعقد البيع إذا كان المبيع عينًا لها منفعة كالعقارات والآلات، والاعتماد المستندي عند إلغاء العميل الاستيراد، وعقد الشركة

والإجارة، وعقود التوريد، وعقود النقل والعمل، وعقد المقاولة المتضمن دفع مبلغ عن كل يوم تأخير.

البيان وسبب الخلاف: الشرط الجزائي في هذه الصورة يتعلق بالتزام المدين بأداء عمل أو تسليم عين أو نحو ذلك، كأن يلتزم المقاول بإنجاز البناء في سنة، فإذا تأخر لزمه مبلغ عن كل يوم تأخير، فهل يشرع هذا الشرط؟ والسبب في الخلاف: **هل هو من الشروط التي تحقق مصلحة العقد وتدخل في عموم وجوب الوفاء بالشروط، أم هو من قبيل الربا أو بيع وشرط أو زيادة منفعة مشروطة لا يقابلها عوض؟** فمن نظر إلى أنه شرط يحقق مصلحة مشروعة للعاقدين أجازه، ومن نظر إلى أن فيه زيادة على العقد الأصلي لا يقابلها عوض منع منه.

الرأي:	البيان:
الأول:	**الجواز** ، ذهب إليه بعض العلماء المعاصرين، وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء في دورتها الخامسة المنعقدة ما بين ٥ و٢٢ من شهر ٨ سنة ١٣٩٤هـ، وقرار دار الإفتاء المصرية، وفتوى الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، وقرار مجمع الفقه الإسلامي.
الثاني:	**عدم الجواز** ، ذهب إليه بعض العلماء المعاصرين.

أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة من الكتاب والسنة والأثر والمعقول.

من الكتاب: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، ووجه الدلالة أنها دلت على وجوب الوفاء بالعقود، والشرط الجزائي من أسباب الوفاء بها.

من السنة: حديث عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا» ، ووجه الدلالة أنه دل على وجوب التزام المسلمين بشروطهم، والشرط الجزائي شرط فكان تنفيذه مباحًا.

من الأثر: ما روي عن عبد الرحمن بن غنم أنه شهد عمر بن الخطاب واختصم إليه في امرأة شرط لها زوجها أن لا يخرجها من دارها فقال عمر: لها شرطها، فقال رجل: لئن كان هكذا لا تشاء امرأة تفارق زوجها إلا فارقته، فقال عمر: المسلمون عند شروطهم عند مقاطع حدودهم؛ وعن ابن سيرين قال: قال رجل لكريه: أرحل ركابك معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: «من شرط على نفسه طائعًا غير مكره فهو عليه»، ووجه الدلالة دلالة الآثار على مشروعيته لوجوب التزام المسلمين بشروطهم.

من المعقول: **الأصل في الشروط الصحة** ، وأنه لا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله، وأنه من الشروط التي تعتبر من مصلحة العقد؛ إذ هو حافز لإكماله في وقته المحدد.

أدلة القول الثاني ومناقشاتها: استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة من السنة والمعقول، ونوقشت.

من السنة: حديث بيعتين في بيعة: حديث أبي هريرة: «نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة» ، ووجه الدلالة عندهم أنه دل على النهي عن بيعتين في بيعة، والشرط الجزائي من قبيل ذلك، ويناقش بأن الاستدلال غير مسلم؛ لأنه ليس من قبيل بيعتين في بيعة ولا من قبيل «بعتك على أن تقرضني أو تزوجني أو تؤجرني»؛ لأن كل واحد من هذه العقود يمكن أن يقع مستقلًا عن العقد الأصلي بخلاف الشرط الجزائي.

من السنة: حديث النهي عن بيع وشرط: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ نهى عن بيع وشرط، ووجه الدلالة عندهم أنه دل على النهي عن بيع وشرط لأنه بيع فاسد يؤدي إلى جهالة الثمن، ولما كان الشرط الجزائي تابعًا للعقد فإنه يكون منهيًّا عنه، ويناقش من وجهين: أن الحديث في إسناده مقال، قال ابن حجر: «واستغربه النووي وقال غريب»؛ وأن اجتماع البيع والشرط إنما يؤدي إلى الربا أو الغرر، واشتراط الشرط الجزائي لا يترتب عليه ذلك.

من المعقول: أن الشرط الجزائي يترتب عليه التزام منفعة زائدة في العقد، وزيادة المنفعة المشروطة لأحد المتعاقدين ربا لأنها زيادة لا يقابلها عوض، ويناقش بأن هناك فرقًا بينه وبين الفائدة الربوية؛ فالفائدة مثبتة في البداية ويلتزم بها المدين ولو لم يتأخر، والشرط الجزائي يدفع عند التأخير والمماطلة، والفائدة تلزم المدين مطلقًا معسرًا أو موسرًا، والشرط الجزائي لا يلزم إلا عند المماطلة إذا كان المدين موسرًا. وأجيب بأن هذه الفروق ليست جوهرية وغير مؤثرة في الحكم الشرعي.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الجواز** ؛ لقوة أدلة القول الأول وضعف دليل المخالف.

- **قوة الأدلة:** لقوة أدلة القول الأول، وظهورها في إثبات المشروعية.
- **ضعف دليل المخالف:** ولضعف دليل القول الثاني، وما ورد عليه من مناقشات.
- **ضمان العاقدين:** ولأنه يحقق ضمانًا لعاقدي العقود مخافة نكول أحدهم عما عقد عليه أو التزمه.
- **سد الضرر:** ويحقق مصلحة ويسد أبواب الفوضى والتلاعب بحقوق العباد وإلحاق الضرر بهم، وعملًا بقوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» ؛ فمفهوم الضرر عام شامل لكل ما يتأذى به المرء في حقوقه التي كفلها له الشارع.
- **جريان العرف:** ولجريان العرف بالتعامل به، والعادة محكمة، وإذا لم يكن فيه ما يوجب تحريمه من ربا أو ظلم أو ميسر فلا وجه لتحريمه بل هو جائز صحيح.

قرار المجمع الفقهي رقم ١٠٩ (٣/١٢): ثالثًا: يجوز أن يكون مقترنًا بالعقد الأصلي كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر، رابعًا: **يجوز اشتراطه في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا؛ فإن هذا من الربا الصريح** ؛ وبناء على ذلك يجوز في عقود المقاولات والتوريد والاستصناع إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه، ولا يجوز في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء كان بسبب الإعسار أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه، خامسًا: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي وما لحق المضرور من خسارة حقيقية وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي، سادسًا: لا يعمل به إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله كان بسبب خارج عن إرادته أو أثبت أن من شرط له لم

يلحقه أي ضرر، سابقًا: يجوز للمحكمة بناءً على طلب أحد الطرفين أن تعدل في مقدار التعويض إذا وجدت مبررًا لذلك أو كان مبالغًا فيه.

قرار هيئة كبار العلماء رقم (٢٥): وتاريخ ٢١ من شهر ٨ سنة ١٣٩٤هـ على أن الشرط الجزائي شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعًا، فيكون العذر مسقطًا لوجوبه حتى يزول؛ وإذا كان كثيرًا عرفًا بحيث يراد به التهديد المالي بعيدًا عن مقتضى القواعد الشرعية وجب الرجوع إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة، أو يرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر.

المسألة الثالثة: في حالة التأخير في سداد الديون:

الدين – معناه وصوره: الدين لغة: دان الرجل يدين دينًا من المداينة، واصطلاحًا: لزوم حق في الذمة؛ فالمال الثابت في الذمة يسمى دينًا، ويسمى مستحق المال دائنًا ومن ثبت في ذمته مدينًا. والعقود التي يكون الالتزام فيها دينًا ثلاثة: **عقد القرض، وعقد البيع بالتقسيط، وعقد السلم** .

1. **المدين المعسر:** هو الذي لا يجد ما يقضي به دينه، وقد **اتفق الفقهاء على وجوب إنظاره** استدلالًا بقوله تعالى: «وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ» ، ولحديث سليمان بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أنظر معسرًا فله بكل يوم مثله صدقة» ، ثم سمعته يقول: «من أنظر معسرًا فله بكل يوم مثليه صدقة» ، فقلت: سمعتك تقول «من أنظر معسرًا فله بكل يوم مثله صدقة» ثم سمعتك تقول «من أنظر معسرًا فله بكل يوم مثليه صدقة» ، قال: «له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة» .

2. **المدين الموسر المماطل:** هو القادر على الوفاء لكنه يماطل **فهو ظالم** ، لحديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «مطل الغني ظلم، وإذا أُتبع أحدكم على مليء فليتبع» .

تعريفه في الديون وخصائصه: هو اتفاق مقترن بعقد يحدد بموجبه العاقدان مسبقًا مبلغًا من المال عند عدم الوفاء بالدين أو التأخر فيه، كفرض غرامة على سداد دين كأقساط بيع سيارة، ومن خصائصه أنه **تقدير جزافي لمبلغ عن ضرر قد يلحق بالدائن** ، وقد يكون أكبر من الضرر أو مساويًا له أو أقل، وأنه اتفاق بين الدائن والمدين في ذات العقد أو في عقد لاحق يرتب على المدين عند إخلاله دفع مبلغ يحدده العاقدان بعد وقوع الضرر، ويختلف حكمه تبعًا لصوره.

1 الصورة الأولى: أن يكون المبلغ مستحقًا دون شرط آخر:

موضع الإجماع: صورتها: أن يقول الدائن: إذا لم يوفه دينه في وقت كذا فله عليه كذا، **ولا خلاف بين الفقهاء على تحريم هذا الشرط وأنه مبطل للعقد؛ لأن ذلك ربا صريح، والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع** .

أدلة التحريم: استدل الفقهاء على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع.

من الكتاب: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» ، ووجه الدلالة أنها دلت على تحريم الزيادة على أصل الدين، قال ابن العربي: «إن الناس في الجاهلية كانوا يتبايعون ويربون، وكان الربا عندهم معروفًا، يبايع الرجل الرجل إلى أجل، فإذا حل الأجل قال: أتقضي أم تربي؟ يعني أم تزيدني على مالي عليك وأصبر أجلًا آخر، فحرم الله تعالى الربا وهو الزيادة».

من السنة: حديث جابر قال: قال رسول الله ﷺ في حجة الوداع: «ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع» ، قال النووي: «في هذه الجملة إبطال أفعال الجاهلية وبيوعها، وقوله في الربا إنه موضوع كله معناه الزائد على رأس المال، كما قال تعالى «وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ» ، لأن الربا هو الزيادة، فإذا وضع الربا فمعناه وضع الزيادة، والمراد بالوضع الرد والإبطال».

الإجماع: حكى ابن عبد البر الإجماع فقال: «أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الربا الذي نزل القرآن بتحريمه هو أن يأخذ الدائن لتأخير دينه بعد حلوله عوضًا عينيًّا أو عرضًا، وهو معنى قول العرب: إما أن تقضي وإما أن تربي»، وقال النووي: «أجمع المسلمون على تحريم الربا وعلى أنه من الكبائر».

قرارات المجامع والمصارف الإسلامية: لا خلاف بين العلماء المعاصرين على تحريمه في هذه الصورة، وقد صدرت فتاوى عن المصارف الإسلامية تؤكد حرمته وتعده ربا نسيئة، ونص قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة على تحريمه وعدم صحته في القرار الثامن: **إن الدائن إذا شرط على المدين، أو فرض عليه أن يدفع مبلغًا من المال غرامة مالية جزائية محددة، وبنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل، سواء أكان الشارط هو المصرف أم غيره، لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه** .

٢ الصورة الثانية: أن يتضمن العقد شرطًا يلزم المدين المماطل بالتعويض عن الضرر الواقع فعلًا:

البيان وسبب الخلاف: صورة المسألة: أن يشترط الدائن على المدين في عقد الدين: إن تأخرت عن السداد مع قدرتك عليه، لزمتك غرامة تعويضًا لي عن الضرر الذي لحقني بسبب تأخيرك، فهل يصح هذا الشرط؟ اختلف العلماء المعاصرون، والسبب في خلافهم: **هل هذا المبلغ الملتزم به تعويض عن ضرر واقع فعلًا فيجوز، أم زيادة في الدين مشروطة فيكون ربا؟** فمن نظر إلى أن المدين الموسر المماطل ظالم، وأن الدائن قد لحقه ضرر حقيقي من جراء تأخره، أجاز التعويض، ومن نظر إلى أن المبلغ المأخوذ زيادة على أصل الدين، والزيادة على الدين مشروطة ربا صريح، منع منه.

الرأي:	البيان:
الأول:	**الجواز** ، وإلزام المدين المماطل بالوفاء به.
الثاني:	**التحريم** ، وبه قال الشيخ علي الخفيف، ود، زكي الدين شعبان، ود، نزيه حماد، ود، محمد شبير، ود، وهبة الزحيلي.

أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة من السنة والأثر والمعقول.

حديث مطل الغني: عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «مطل الغني ظلم» ، ووجه الدلالة أنه دل على أن المدين المماطل ظالم، فهو بامتناعه عن السداد مع القدرة كالغاصب فوجب تحمله الشرط الجزائي عند المماطلة، ويناقش بأن الأصول الشرعية تقضي بأن أخذ المال لا يكون إلا تبرعًا أو في مقابلة مال وإلا كان أكلًا له بالباطل؛ لأن أصل التعويض في نظر فقهاء الشريعة مقابلة المال بالمال.

حديث لي الواجد: عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» ، ووجه الدلالة عندهم أنه دل على أن المدين الغني المماطل ظالم يحل عرضه وعقوبته، والعقوبة تشمل الحبس والضرب فيقاس عليه الغرامة المالية، ويناقش بأن مقصود الحديث شكايته وحبسه لا تغريمه بالمال؛ لأن التغريم من الربا الحرام وهو ربا النسيئة، قال النووي: قال العلماء يحل عرضه بأن يقول ظلمني ومطلني، وعقوبته الحبس والتعزير.

أثر ابن سيرين: أن رجلًا قال لكريه: أرحل ركابك معك، فإن لم أرحل يوم كذا وكذا فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: «من شرط على نفسه طائعًا غير مكره فهو عليه».

من المعقول: أن تعويض الدائن عن ضرره الناتج عن التأخير مبدأ مقبول شرعًا؛ لأنه لا ينافي نصوص الشريعة ومقاصدها العامة، وقياس وجوب تضمين المدين على تضمين الغاصب منافع الأعيان المغصوبة، ويناقش بأن هناك فروقًا جوهرية بين النقود والأعيان؛ فالأعيان يمكن الاستفادة من منافعها ولذلك يجوز تأجيرها بمال، أما النقود فليست لها منافع بذاتها فلا يجوز تأجيرها.

أدلة القول الثاني ومناقشاتها: استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة من السنة والمعقول.

حديث بيعتين في بيعة: حديث أبي هريرة: «نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة» ، ووجه الدلالة عندهم أن الشرط الجزائي من قبيل ذلك، ويناقش بأن الاستدلال غير مسلم؛ لأنه ليس مستقلًا عن العقد الأصلي وإنما هو من قبيل الاحتياط في إكماله بالوفاء بالشرط.

حديث النهي عن بيع وشرط: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ نهى عن بيع وشرط، ووجه الدلالة عندهم أنه دل دلالة صريحة على النهي عن بيع وشرط لأنه بيع فاسد يؤدي إلى جهالة الثمن، والنهي يقتضي تحريم المعاملة، ولما كان الشرط الجزائي تابعًا للعقد فإنه يكون منهيًّا عنه، ويناقش من وجهين: أن الحديث في إسناده مقال قال ابن حجر: «واستغربه النووي وقال غريب»؛ وأن اجتماع البيع والشرط إنما يؤدي إلى الربا أو الغرر، واشتراط الشرط الجزائي لا يترتب عليه ذلك.

من المعقول: الشرط الجزائي على التأخير ربا نسيئة محرم؛ لالتزام زيادة مشروطة بلا عوض، والفرق بينه وبين الفائدة غير جوهري، وكون الفائدة طريقًا استثماريًّا لا يغير الحكم؛ فالشرط الجزائي إعادة توازن لا استثمار.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو التحريم** ؛ لأن الشرط الجزائي في الديون ربا؛ إذ كل زيادة في الدين مشروطة ربا صريح.

الزيادة في الدين ربا: إذ كل زيادة في الدين مشروطة ربا صريح.

المشكلة قديمة: ولأن مشكلة تأخر الديون ليست وليدة عصرنا بل كانت موجودة ومع ذلك لم ينقل إلينا أن أحدًا أجاز اشتراط الزيادة على الديون.

البدائل الشرعية كثيرة: والبدائل الشرعية كثيرة.

قرار المجمع الفقهي رقم ٥١ (٦/٢): **إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم** ؛ ويحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعًا اشتراط التعويض في حالة التأخير عن الأداء؛ وجاء في الفقرة الخامسة: **يجوز شرعًا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخير المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد** .

قرار المجمع رقم ٨٥/٢/٩ بشأن السلم: أصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي من ١ إلى ٦ من ذي القعدة ١٤١٥هـ الموافق ١ إلى ٦ من نيسان سنة ١٩٩٥م القرار رقم ٨٥/٢/٩ بشأن السلم وتطبيقاته المعاصرة: **لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عن التأخير** .

الإجارة المنتهية بالتمليك:

١ تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك ونشأتها
٢ صور العقد الخمس
٣ المسائل الفقهية المرتبطة به
٤ التكييف والحكم وقرار المجمع

١ تعريف الإجارة ومشروعيتها:

الإجارة لغةً: مشتقة من الأجر، ومعناها الجامع أن أجرة العامل كأنها شيء يجبر به حاله فيما لحقه من كدّ.

المذهب:	التعريف:
الحنفية:	عقد على المنفعة بعوض هو مال .
المالكية:	تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض .
الشافعية:	عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم .
الحنابلة:	عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل بعوض معلوم .

ملاحظات على التعريفات: ويلاحظ أن تعريف الحنفية خلا من قيد إباحة المنفعة ومدة الانتفاع المعلومة والأجرة المعلومة، وتعريف المالكية خلا من قيد كون المعوض معلومًا، وتعريف الشافعية قيد المنفعة بكونها مقصودة، أما تعريف الحنابلة فجامع لنوعي الإجارة: إجارة المنافع وإجارة الأعمال، ولإجارة العين المرئية والموصوفة في الذمة، وإن خلا من قيد كون المنفعة مقصودة.

أدلة المشروعية: وثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والمعقول.

من الكتاب: «قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ» ، وقوله: «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» ؛ ووجه الدلالة في الأولى أن نبيًّا أَجَّر نفسه حِجَجًا مسماة فدل على جوازها؛ لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ، وفي الثانية جواز الإجارة على الرضاع.

من السنة: حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ» ، وحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: قال الله تعالى: «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ» ، وفي معناهما بقية الأحاديث الواردة في الباب.

الإجماع: نقله ابن قدامة في المغني والكاساني في البدائع؛ قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة، إلا ما يحكى عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال: لا يجوز ذلك لأنه غرر، وهذا غلط لا يمنع انعقاد الإجماع، وقال الكاساني: فإن الأمة أجمعت على ذلك قبل وجود الأصم فلا يعبأ بخلافه.

القياس: قياس الإجارة على البيع؛ فلما جاز العقد على الأعيان وجب جواز العقد على المنافع؛ لأن حاجة الناس إلى المنافع كحاجتهم إلى الأعيان.

المعقول: لأن كل واحد قد لا يملك دارًا يسكنها أو أرضًا يزرعها وقد لا يمكنه تملكها بالشراء أو الهبة، فشرع التشريع لكل حاجة عقدًا: البيع لتمليك العين بعوض، والهبة لتمليكها بغير عوض، والإعارة لتمليك المنفعة بغير عوض، والإجارة لتمليك المنفعة بعوض، ولو لم تشرع مع مساس الحاجة إليها لتعذر دفعها.

أقسام الإجارة: وينقسم عقد الإجارة باعتبار المعقود عليه إلى نوعين: **إجارة على منافع الأعيان** ، وتشمل العقار والعروض والدواب، وتنقسم إلى إجارة على أعيان مرئية يشترط فيها ما يشترط لصحة البيع، وإجارة أعيان موصوفة في الذمة يشترط لها ما يشترط للسلم؛ و **إجارة على الأعمال** كاستئجار أصحاب الحرف، وينقسم إلى أجير خاص وأجير مشترك.

2 تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك ومصطلحاتها ونشأتها:

التمليك اصطلاحًا: اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقًا لتصرفه فيه وحاجزًا عن تصرف غيره فيه، وعرفه القرافي بأنه **حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة يقتضي تمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه** ، والتمليك قد يكون للعين أو للمنفعة وبعوض أو بغيره: فتمليك العين بغير عوض هبة، وبعوض بيع، وتمليك المنفعة بعوض إجارة، وبغير عوض عارية.

التعريف المركب: **عقد إجارة يقترن بها وعد بتمليك العين المؤجرة إلى المستأجر في نهاية مدة الإجارة أو أثنائها** ، وقيل: عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما الآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سداده لآخر قسط بعقد جديد.

المصطلحات المقابلة: ويطلق عليه: البيع الإيجاري، والإيجار الساتر للبيع، والإيجار الذي ينقلب بيعًا، والإيجار المقترن بوعد بالبيع.

نشأته: نشأ في إنجلترا عام ١٨٤٦م، وأول من تعامل به تاجر للآلات الموسيقية، ثم انتقل إلى الشركات والمصانع فعملت به شركة سنجر لآلات الخياطة، ثم تطور وتناوله فقهاء القانون تحت مسميات الإيجار الساتر للبيع أو البيع الإيجاري أو الإيجار المملك، ثم انتقل إلى الدول الإسلامية من خلال البنوك الإسلامية.

3 الفروق بينه وبين بعض عقود المعاوضات ومزاياه:

الفرق عن البيع والإجارة التشغيلية: يفترق عن البيع والإجارة التشغيلية في أن البيع والإجارة من العقود اللازمة، إلا أن البيع وارد على العين ومنفعتها بينما الإجارة تنتقل فيها ملكية المنفعة فقط مدة العقد دون العين؛ وفي الإجارة لا يلتزم المستأجر بشراء العين بل يمكنه إنهاء العقد بغير تبعات مالية؛ والمخاطر ونفقاتها في الإجارة التشغيلية من مسؤولية المؤجر بلا خلاف؛ ومدة الإجارة التشغيلية قد تقصر عن العمر الإنتاجي للأصل وقد تصل إليه؛ والأعيان المؤجرة فيها تعود إلى حيازة البنك المؤجر بعد انتهاء العقد ويتحمل المالك مخاطر ركود السوق.

NARA 01105405478

أ أهم ما يتميز به:

- **عقد مركب:** **أنه عقد مركب يجمع بين الإيجار والوعد بالبيع في بعض صوره** .
- **التزام المستأجر:** ويلتزم المستأجر بسداد الأقساط المتفق عليها وقد يتعرض لخسارة ما دفعه إذا لم يتمكن لأن الأقساط قد تتضمن جزءًا من ثمن السلعة.
- **الصيانة:** ونفقات الصيانة من مسؤولية المستأجر.
- **نهاية العقد:** وينتهي في معظم صوره بتملك المستأجر العين بوعد أو عقد بثمن محدد رمزي أو حقيقي أو حسب سعر السوق أو بمنحه حق اختيار الشراء.
- **المدة:** ومدة الإيجار قد تصل أو تقارب العمر الإنتاجي للسلعة.
- **انتقال الملكية:** وبعد انتهاء المدة تنتقل العين إلى ملكية المستأجر في أغلب صورها.

الفرق عن البيع بالتقسيط: أن الملكية في البيع بالتقسيط تنتقل بمجرد إبرام العقد وله حرية التصرف على أن يسدد الثمن أقساطًا وهو عقد واحد، بخلاف الإجارة المنتهية بالتمليك فلا تنتقل الملكية إلا بعد انتهاء الإجارة وإبرام عقد التمليك؛ وفي البيع بالتقسيط تكون الأقساط دينًا لازمًا في ذمة المشتري بعد العقد أما في الإجارة المنتهية بالتمليك فتعد دفعات الإجارة ديونًا غير مستقرة إلا بعد التمكن من استيفاء المنفعة؛ وفي البيع بالتقسيط تثبت ملكية البائع للدين الذي في ذمة المشتري فلا يجوز بيع هذا الدين ولا تصكيكه لأنه من تداول الديون، بينما في الإجارة المنتهية بالتمليك تبقى ملكية المؤجر للأعيان المؤجرة فيجوز تصكيك هذا الحق.

ب مزايا المستأجر:

- **الحيازة والانتفاع:** حيازة الأصل والاستفادة منه مع عدم قدرته على دفع الثمن نقدًا.
- **تحسين السيولة:** عدم تجميد جزء كبير من رأسه ماله مما يحسن مركز السيولة لديه.
- **اقتناء معدات حديثة:** اقتناء معدات حديثة قد لا تتوافر له إمكانية شرائها.
- **تمويل كامل:** تمويل كامل للأصول المستأجرة.
- **تفادي القيود:** تفادي القيود التي تلتزم بها البنوك في تمويل المشروعات.
- **تجنب الضرائب:** تجنب الضرائب التي قد تفرض على بعض الملاك.

ALAA 01103406478

عدم الإرهاق بالديون: عدم إرهاق المستأجر بالديون إذ لا تظهر قيمة الأصل في ميزانيته.

ج مزايا المؤجر:

الصيانة على المستأجر: يحمل المستأجر تكاليف الصيانة مع تحمل تكلفة التأمين.

حق الرقابة: يحتفظ بحق الرقابة واسترجاع الأصل عند عدم سداد الأقساط.

عدم مزاحمة الغرماء: عدم مزاحمة الغرماء في العين المؤجرة عند إعسار المستأجر.

المرونة: توفر شروط التعاقد مرونة كبيرة.

توفير التكاليف: تمليك المعدات بعد سداد كامل الأقساط يوفر تكاليف التفكيك والإرجاع.

د مزايا الاقتصاد القومي:

إتاحة الأصول: إتاحة الأصول والمعدات مما يساعد على إنشاء مشروعات إنتاجية أو توسيع القائم منها.

فرص العمالة: زيادة فرص تشغيل العمالة والحد من البطالة.

الصناعات المتقدمة: التعجيل بإقامة صناعات متقدمة أكثر إنتاجية.

4 صور عقد الإجارة المنتهية بالتمليك:

1 **الصورة الأولى:** أن يصاغ العقد على أنه عقد إيجار ينتهي بتملك الشيء المؤجر إذا رغب المؤجر في ذلك مقابل المبالغ التي دفعت فعلًا كأقساط إيجار خلال المدة المحددة، ويصبح المستأجر مالكًا بمجرد سداد القسط الأخير دون حاجة إلى عقد جديد؛ وصياغته: أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر أو عام هي كذا لمدة ثلاث سنوات على أنك إذا وفيت بهذه الأقساط جميعها كان الشيء المؤجر ملكًا لك مقابل ما دفعته من أقساط الأجرة، فالعقد إجارة تنتهي بتمليك العين دون دفع ثمن سوى الأقساط الإيجارية.

MNARA 01105405478

2 **الصورة الثانية:** أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين في مقابل أجرة محددة في مدة محددة، على أن يكون له الحق في تملك العين في نهاية المدة مقابل دفع مبلغ هو كذا؛ فالعقد اشتمل على إجارة للعين مدة محددة ثم بيعها في نهاية المدة بثمن رمزي أو حقيقي، والثمن الرمزي روعي فيه أن الأقساط تعادل في مجموعها ثمن السلعة الحقيقي مع الربح، ووضع رمزيًّا لهدفين: إظهار أن الاتفاق كان في البداية عقد إجارة وأنه في النهاية عقد بيع، والعقد في هذه الصورة اشتمل على عقدين: **عقد ناجز هو الإجارة اقترن به شرط فاسخ يبدأ بعده البيع، وعقد بيع معلق على شرط** .

3 **الصورة الثالثة:** أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين في مقابل أجرة محددة، على أن المؤجر يعد المستأجر وعدًا ملزمًا إذا وفى بسداد الأقساط الإيجارية في المدة المحددة ببيع العين في نهاية العقد بمبلغ معين؛ فالعقد إجارة مقترنة بوعد بالبيع.

4 **الصورة الرابعة:** أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين في مقابل أجرة محددة في مدة محددة، على أن المؤجر يعد وعدًا ملزمًا بهبة العين للمستأجر إذا وفى بسداد الأقساط في المدة المحددة في نهاية العقد؛ فالعقد إجارة مقترنة بوعد بهبة العين.

5 **الصورة الخامسة:** أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين في مقابل أجرة محددة في مدة محددة، مع وعد ملزم من المؤجر بأن يجعل للمستأجر في نهاية المدة الحق في أحد ثلاثة أمور: تملك السلعة مقابل ثمن يراعى في تحديده المبالغ المدفوعة كأقساط، وهذا الثمن محدد عند بداية التعاقد أو بأسعار السوق عند نهاية العقد؛ أو مد عقد الإجارة لفترة أخرى؛ أو إعادة الأعيان المؤجرة إلى المؤسسة المالكة، فالعقد مقترن بوعد التخيير بين التملك أو مد المدة أو إعادة العين.

المسألة الأولى: حكم اجتماع البيع والإجارة في عقد واحد:

البيان وسبب الخلاف: قبل بيان حكم عقد الإجارة المنتهية بالتمليك يلزم بحث حكم إبرام معاقدة تشتمل على عقدي البيع والإجارة بحيث تعتبر موجباتهما وجميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليهما جملة واحدة، والسبب في الخلاف: التردد في فهم حديث النهي عن بيعتين في

بيعة بين العمل بمفهومه أو بظاهره؛ فمن حمله على معنى أعمق ذهب إلى الجواز، ومن حمله على ظاهره ذهب إلى منع اجتماع العقود في صفقة واحدة.

الرأي:	البيان:
الأول:	**الجواز** ، سواء كان محل العقد واحدًا أو مختلفًا بثمن واحد؛ وهو قول جمهور الفقهاء المالكية عدا سحنون، وأصح القولين عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية، واشترط ابن القاسم في مذهبه وروايته عن مالك أن جواز اجتماع البيع والإجارة في عين واحدة في إجارة الأعمال أن يعرف وجه خروج هذا العمل من كونه رديئًا أو جيدًا أو يمكن إعادته إن لم يرض به المؤجر.
الثاني:	**عدم الجواز** ، وهو قول الحنفية، والشافعية في وجه، ورواية للحنابلة، ووافقهم سحنون من فقهاء المالكية فيما إذا كان محل العقد واحدًا في الإجارة على الأعمال، أما إذا كان محل العقد مختلفًا جاز اجتماعهما.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بأن **الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة** ولا يحرم ويبطل منها إلا ما دل على تحريمه وإبطاله نص أو قياس، وأن البيع والإجارة كل منهما عقد يصح إفراده فصح جمعهما، وليس في اجتماعهما أكثر من اختلاف حكمهما وهذا لا يمنع صحة العقد ويقسم العوض عليهما.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة من السنة.

حديث بيعتين في بيعة: حديث أبي هريرة: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» ، أي صفقة واحدة وفي عقد واحد.

حديث السلف والبيع: وحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» ، ووجه الدلالة أن ظاهر الحديث يدل على أن اشتراط عقد في عقد آخر شرط فاسد يفسد به العقد.

المناقشات: نوقش الاستدلال بهذين الحديثين من أوجه: أن المراد عدم الجمع بين معاوضة وتبرع؛ وأن المراد ببيعتين في بيعة أن يملك الرجل السلعة بثمنين عاجل وآجل؛ وأن الحديث لا يؤخذ

على ظاهره لأن الأصل في العقود الإباحة ما لم يؤد إلى مآل ممنوع، ونوقش دليل الرأي الأول المعقول بأن اختلاف حكم العقدين لا يمنع صحة العقد، كما لو جمع في البيع بين ما فيه شفعة وما ليس فيه.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الأول** ، القائل بجواز اجتماع البيع والإجارة في عقد واحد.

التيسير على الناس: لما في هذا القول من التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم.

قوة الأدلة: ولقوة ما استدل به أصحاب هذا الرأي من الكتاب والسنة والمعقول.

شروط الجواز: غير أن الجواز مشروط بتحديد مدة الإجارة، والشروع في العمل أو في حكمه، والعلم بصفة العمل.

قياس لا يصح: أما قياس اجتماع إجارة على عين مع بيع على هذه العين الواحدة المؤجرة المعلق على الوفاء بكامل ثمن المنفعة على الصورة التي ذكرها الفقهاء فلا يصح؛ لأن الصورة المذكورة إجارة باتة ناجزة وبيع بات ناجز، ليس معلقًا على شرط ولا مضافًا إلى أجل، على محلين مختلفين، كما أن الضوابط المذكورة في الإجارة على العمل لا يلزم تحققها في الإجارة المنتهية بالتمليك.

المسألة الثانية: حكم إلزام المستأجر نفقات الصيانة والتأمين:

موضع الاتفاق: اتفق الفقهاء على أن **يد المستأجر على العين المؤجرة يد أمانة** ، فإذا تلفت بلا تعد أو تقصير لم يضمنها، لما روي عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ» ، ولأن العين قبضها المستأجر ليستوفي منها منفعتها فلم يضمنها بالقبض.

ما اتفق على منعه: واتفقوا على أنه **لا يجوز للمؤجر اشتراط الضمان على المستأجر** وإلا كانت الإجارة فاسدة؛ لأن تكاليف الضمان مجهولة، فقد يتكلف الكثير أو القليل أو لا يتكلف شيئًا حسب الأعطال، وهذه جهالة مفسدة للعقد، وجاء في الموسوعة الفقهية: «ولا يجوز اشتراط صيانة العين على المستأجر، لأنه يؤدي إلى جهالة الأجرة، فتفسد الإجارة بهذا الاشتراط باتفاق المذاهب».

مخالفة الزيدية: خالف الزيدية فقالوا: المستأجر ضامن للعين المؤجرة، عملًا بقول الرسول ﷺ فيما رواه سمرة: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ» ، ولأن المستأجر رضي لنفسه الانتفاع بالعين فكان رضاه محللًا لماله الذي دفعه في ضمانها.

قول المعاصرين: وبناءً على قول جمهور الفقهاء بأن ضمان العين المؤجرة على المالك، ذهب أكثر العلماء المعاصرين إلى أن **نفقات الصيانة غير التشغيلية والتأمين في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك لا تجب على المستأجر وإنما تجب على المؤجر** ، سواء كان مصرفًا أو شركة، فهو مطالب بالإبقاء على العين بحالة يستطيع المستأجر استيفاء منافعها، وللمؤجر أن يوكل المستأجر للقيام بذلك ثم يخصم من قيمة الأجرة، ولا مانع أن يزيد في الأجرة لتغطية النفقات، أما إذا قام بها المستأجر دون إذن فهو متبرع.

قول قحف والقرة داغي: أجاز كل من د. منذر قحف ود. محي الدين القرة داغي اشتراط ضمان العين ونفقات الصيانة الجوهرية التي تتعلق بتمكين المستأجر من الانتفاع على المستأجر عند التعاقد؛ لأنه شرط لا يخالف نصًّا، والأفضل أن يخصم المبلغ من الإجارة خروجًا من الخلاف، أما غير المعلوم من نفقات الإصلاح فلا يصح اشتراطه لأنه يدخل جهالة في مقدار الأجرة، ونفقات التأمين إذا كانت معلومة يجوز اشتراطها على المستأجر واعتبارها جزءًا من الأجرة لأن التأمين التعاوني قائم على التبرع.

قرار المجمع: اعتمد قرار مجمع الفقه الإسلامي في الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم جواز اشتراط ضمان العين المؤجرة على المستأجر، وجاء في قرار آخر أن **الصيانة التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة تلزم المؤجر ولا يجوز اشتراطها على المستأجر** ، بخلاف الصيانة التي لا يتوقف عليها استيفاء المنفعة فيجوز اشتراطها على أي منهما إذا عينت تعيينًا نافيًا للجهالة.

المسألة الثالثة: حكم بيع المؤجر العين المؤجرة للمستأجر:

موضع الاتفاق: لا خلاف بين الفقهاء على **صحة بيع المؤجر العين المؤجرة للمستأجر** ؛ لأن العين في يد المستأجر لا حائل دونها فصح بيعها منه كما لو باع المغصوب من الغاصب، ولأن ملك الرقبة حق خالص للبائع وعقد الإجارة ورد على المنفعة فلا يمنع من بيع الرقبة.

محل الخلاف: واختلفوا في أثر ذلك على عقد الإجارة على رأيين.

الرأي:	البيان:
الأول:	**لا ينفسخ عقد الإجارة** ، بل يستوفي المستأجر المنفعة إلى انتهاء مدتها ثم يتملكها بعقد البيع، فإن تلفت المنافع قبل انقضاء المدة انفسخت ورجع المشتري بالأجرة لما بقي على البائع؛ وهذا قول للمالكية، والشافعية في الأصح، ورواية للحنابلة، واشترط المالكية أن يبقى من مدة الإجارة ما لا يكون غررًا يخاف تغيرها في مثله.
الثاني:	**فسخ الإجارة فيما بقي من المدة** ، ويسقط عن المشتري الأجر فيما بقي ويحسب من الثمن؛ وهذا قول جمهور الحنفية، وبعض المالكية، والشافعية في وجه، والحنابلة في رواية.

دليل الرأي الأول: أن المستأجر ملك المنافع أولًا ملكًا مستقرًّا فلا يبطل بما يطرأ من ملك العين، وأنه تملك المنفعة بعقد ثم ملك الرقبة بعقد آخر فلم يتنافيا.

دليل الرأي الثاني: قياس فسخ الإجارة بملك العين على فسخ النكاح بملك اليمين، ولأن الإجارة عقد على منفعة الرقبة فإذا ملك الرقبة بطل العقد على منفعتها، واستدلوا على سقوط الأجرة بالقياس على تلف العين.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الثاني** ، القائل بفسخ الإجارة فيما بقي من المدة.

قوة ما استدل به أصحاب الرأي الثاني: لقوة ما استدل به أصحاب الرأي الثاني، من قياس فسخ الإجارة بملك العين على فسخ النكاح بملك اليمين، ومن أن الإجارة عقد على منفعة الرقبة فإذا ملكت الرقبة بطل العقد على منفعتها.

ضعف دليل الرأي الأول: ولضعف دليل الرأي الأول أمام ما استدل به أصحاب الرأي الثاني.

المسألة الرابعة: حكم الوفاء بالوعد:

البيان وسبب الخلاف: الوعد هو ما يلتزم به المرء لغيره من غير أن يكون عقدًا ملزمًا في ذاته، والوعد بالتمليك هو أساس عقد الإجارة المنتهية بالتمليك في أغلب صوره، فمن ثم كان لا بد من بيان حكمه؛ والسبب في اختلاف الفقهاء فيه: التوفيق بين نصوص تأمر بالوفاء بالعهود وتذم إخلاف الوعد وتعدّه من صفات المنافقين، وبين نصوص أخرى تنفي الإثم عن مخلف الوعد، فمن رجّح جانب الأمر بالوفاء أوجب، ومن رجّح جانب نفي الإثم استحب، ومن جمع

حمل نصوص الوجوب على حالة ارتباط الوعد بسبب دخل فيه الموعود، وحمل نصوص نفي الإثم على غيرها، ومن حملها على العموم مع استثناء العذر أوجب مطلقًا. وعلى هذا التصور جاءت أربعة آراء.

الرأي:	البيان:
الأول:	**الوفاء بالوعد مستحب** ، فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيهية شديدة لكنه لا يأثم؛ وبه قال جمهور الحنفية إذا لم يكن معلقًا، وبعض المالكية، والشافعية، والحنابلة في رواية، ووافقهم الظاهرية، وقال الحنفية بلزوم الوفاء بالوعد إذا كان معلقًا، كما لو قال شخص لآخر: بع هذا الشيء لفلان وإن لم يعطك الثمن فأنا أعطيه لك، فلم يعط المشتري الثمن لزم الواعد أداء الثمن وفاء بوعده.
الثاني:	**وجوب الوفاء بالوعد إذا ارتبط بسبب ودخل الموعود في السبب** ، أما إذا لم يباشر الموعود السبب فلا شيء على الواعد، كما لو قال: اهدم دارك وأنا أسلفك، فهدمها، أو اخرج للحج فخرج، أو تزوج امرأة وأنا أسلفك، فتزوج اعتمادًا على الوعد، فيلزم الواعد قضاء؛ وهذا هو المشهور والراجح في مذهب مالك، وعزاه القرافي إلى مالك وابن القاسم وسحنون.
الثالث:	**وجوب الوفاء بالوعد قضاء إذا ارتبط الوعد بسبب، سواء دخل الموعود في السبب أو لم يدخل** ، كما لو قال شخص لآخر: أعدك بأن أقرضك كذا لتتزوج، أو قال الموعود: أريد أن أقضي ديني أو أتزوج فأقرضني مبلغ كذا فوعده ثم رجع قبل أن يباشر الموعود السبب، فإن الواعد ملزم بالوفاء ويحكم عليه به؛ وبه قال أصبغ من فقهاء المالكية.
الرابع:	**الوفاء بالوعد واجب إلا لعذر** ، وهو قول بعض المالكية منهم ابن العربي، والإمام أحمد في رواية ثانية، وهو قول بعض السلف منهم عمر بن عبد العزيز وإسحاق بن راهويه وابن شبرمة حكاه عنه ابن حزم، وبه قال الإمام الغزالي.

دليل الرأي الأول: حديث زيد بن أرقم عن النبي ﷺ: «إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ لَهُ فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيعَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ» ؛ وحديث صفوان بن سليم أن رجلًا قال لرسول الله ﷺ: أكذب امرأتي يا رسول الله؟ فقال: «لَا خَيْرَ فِي الْكَذِبِ» ، فقال الرجل: يا رسول الله أعدها وأقول لها؟ فقال: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكَ» ؛ ووجه الدلالة نفي الإثم عن مخلف الوعد، ونوقش بأن ذلك يحمل على أنه لم يف مضطرًّا جمعًا بين الأدلة، واستدل الحنفية على لزوم الوعد المعلق بقوة الارتباط بين الشرط والجزاء.

دليل الرأي الثاني: الجمع بين النصوص التي أوجبت الوفاء وبين ما لم يجعل إخلاف الوعد كذبًا، فحملت النصوص على هذا التفصيل.

دليل الرأي الثالث: أن ذكر السبب مرتبطًا بالوعد يتأكد به العزم على الدفع.

دليل الرأي الرابع: قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ» ، ووجه الاستدلال أن كل من ألزم نفسه قربة أو عقدًا لزمه الوفاء به إلا أن يكون معصية؛ وحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» ؛ وحديث ابن عباس عن النبي ﷺ: «لَا تُمَارِ أَخَاكَ، وَلَا تُمَازِحْهُ، وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدَةً فَتُخْلِفَهُ» ؛ ووجه الدلالة ذم إخلاف الوعد وعدّه من صفات المنافقين وظاهره التحريم، وناقش ابن حزم الاستدلال بأن من وعد بما لا يحل أو عاهد على معصية فلا يحل له الوفاء فليس كل من وعد فأخلف مذمومًا.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الرابع** ، القائل بأن الوفاء بالوعد واجب مطلقًا إلا لعذر.

الجمع بين الأدلة: جمعًا بين الأدلة الدالة على وجوب الوفاء، وما ورد من نفي الإثم عن مخلف الوعد محمول على العذر.

جبر الواعد قضاء عند الضرر: ويجبر الواعد على الوفاء قضاء إذا ترتب عليه ضرر يلحق بالموعود، تحقيقًا للعدل ومنعًا للإضرار بالناس.

المسألة الخامسة: حكم الصورة الأولى – التمليك التلقائي:

تصوير المسألة: في هذه الصورة تنتقل ملكية العين إلى المستأجر بمجرد الانتهاء من دفع آخر قسط دون عقد جديد، وبالنظر إليها يتضح أن صيغ العقد في البداية إجارة بلفظ «أجرتك» وللمؤجر سحب العين إذا قصر المستأجر في الأقساط مما يدل على الإجارة، واجتمع مع الإجارة بيع يدل عليه أن المستأجر ضامن لنفقات الصيانة والتأمين وتبعات التلف ثم تنتقل الملكية تلقائيًا بعد سداد الأقساط وتعتبر الأقساط في الحقيقة ثمنًا للسلعة.

- **مأخذ أول:** أن كل مبيع لا بد له من ثمن وفي هذه الصورة لا يوجد ثمن وقت تمام البيع.
- **مأخذ ثانٍ:** تحويل الأقساط بعد ذلك إلى ثمن بعقد لاحق لا يسير مع القواعد الشرعية في أن لكل عقد أحكامه وآثاره فور انعقاده.
- **مأخذ ثالث:** أن أجرة المنفعة ليست أجرة المثل بل روعي فيها أن تكون ثمن السلعة.
- **مأخذ رابع:** أن إرادة المتعاقدين متجهة إلى بيع السلعة وليس إجارتها.

الرأي:	البيان:
الأول:	**العقد بيع بالتقسيط** ، وبه قال بعض العلماء المعاصرين منهم د. عبد الله محمد عبد الله، ود. رفيق يونس، والشيخ إبراهيم أبو الليل، ود. أحمد دنيا؛ ووجهه أن آثار العقد ملكية، والملكية لا تكون بلا ثمن، والأقساط لا تتناسب مع أجرة المثل بل روعي فيها قيمة المبيع مؤجلًا، وإرادة المتعاقدين تتجه إلى تملك السلعة لا إجارتها، فصيغ العقد بهذه الصورة لحماية حق المالك من نكول المشتري، فلا يمكن وصفه إلا ببيع يتملك فيه العاقد الرقبة والمنفعة.
الثاني:	**أنها تشتمل على عقدين: إجارة وبيع معلق على سداد الأجرة** ، واعترض بأن الأقساط دفعت أجرة فكيف تتحول إلى ثمن في نهاية المدة.

الرأي:	البيان:
الأول:	**عدم الجواز** ، وهو قول أكثر العلماء المعاصرين منهم د. عبد الله محمد عبد الله، ود. حسن الشاذلي، ود. عبد الله الشيخ المحفوظ بن بيه، ود. وهبة الزحيلي، ود. سعد بن تركي الخثلان، والشيخ حامد بن عبد الله العلي، ود. خالد المشيقح، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي وأفتت به اللجنة الدائمة.

الثاني: **الجواز** ، وبه أفتى بعض العلماء المعاصرين منهم الشيخ محمد بن جبير، ود، محمد جبر الألفي، ود، سعد بن ناصر الشثري.

دليل المنع: حديث: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» ، وحديث: «نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» ، ووجه الدلالة اشتمال العقد على بيع وإجارة في آن واحد على عين واحدة، ولأن العقد بهذه الخصائص غرر ومجازفة، فقد يعسر المشتري في آخر قسط وقد دفع أقساطًا لا تناسب الإجارة فيخسر الثمن والمثمن.

دليل الجواز: أن العقد في حقيقته بيع بالتقسيط والصيغة ستر للعقد الحقيقي والعبرة في العقود بالحقائق، ولأنه بيع أدرج فيه شرط جزائي وهو عدم انتقال الملكية إلا بعد الوفاء بكافة الأقساط، والأصل في الشروط الصحة إلا ما دل الدليل على منعه، بناء على ما روي عن الإمام أحمد بجواز تعليق البيع على شرط، ونوقش بأن العين من ضمان المؤجر مما يدل على أن المقصود الإجارة وليست صورية، وبأن شرط عدم نقل الملكية يناقض مقتضى البيع، وأجيب بأن الشرط المنافي لمقتضى العقد صحيح إذا كان لأحد المتعاقدين قصد صحيح كحفظ حق البائع.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الأول** ، القائل بعدم جواز عقد الإجارة المنتهية بالتمليك تلقائيًا بتلك الصيغة.

قوة أدلة المنع: لقوة أدلة المنع، من حديث النهي عن بيعتين في بيعة، وحديث النهي عن سلف وبيع، واشتمال العقد على بيع وإجارة في آن واحد على عين واحدة.

الغرر والمجازفة: ولأن العقد بهذه الخصائص غرر ومجازفة، فقد يعسر المشتري في آخر قسط وقد دفع أقساطًا لا تناسب الإجارة فيخسر الثمن والمثمن.

البديل الشرعي: يمكن إيجاد بديل شرعي بأن يفصل بين العقدين بحيث يتبع عقد الإجارة عقد البيع فيستقل كل منهما عن الآخر، وفق شروط: **أن يكون ضمان العين من المؤجر المالك لها** ويمكن أن يتحمله المستأجر نيابة عن المؤجر مع خصمه من القيمة الإيجارية وليست على المستأجر إلا في التعدي أو التقصير، ونفقات التشغيل على المستأجر؛ وللمؤجر أن يشترط شرطًا جزائيًا تعويضًا عن الضرر عند عدم الوفاء بالأقساط بقدر رفع الضرر؛ وأن يكون التأمين تعاونيًا إسلاميًا لا تجاريًا؛ وأن تصاغ العقد على أنه بيع له غنمه وعليه غرمه معلق على

شرط الوفاء بجميع الثمن، فإذا سداد الأقساط انطلق حق الملكية ليضاف إلى حق المنفعة، ومن حق المالك استرداد العين عند عدم الوفاء مع خصم القيمة الحقيقية لإجارة العين ورد ما زاد، وتعليق البيع على شرط موافق لما ذهب إليه بعض المالكية وأحمد في رواية، عملًا بعموم قوله ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» ، أو **أن يضاف وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة** .

دليل تعليق البيع على شرط: عموم قوله ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» ، وبما روي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال في غزوة مؤتة: «إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ» ، وعلق عقد الولاية على أمر في المستقبل.

المخرج النبوي: أرشد الرسول ﷺ إلى المخرج الذي يتحقق به الغرض من غير محظور فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: أنه استعمل رجلًا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله ﷺ: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟» قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله ﷺ: «لَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا» ، وهو ما أقره مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة.

المسألة السادسة: حكم الصورة الثانية – التمليك بثمن رمزي:

الأصل في البيع بأقل من الثمن: لا خلاف بين جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن البيع إذا صدر ممن هو أهل للتصرف بأن كان بالغًا عاقلًا مختارًا رشيدًا يحسن التجارة وكان تصرفه فيما يملك كان صحيحًا، سواء كان بثمن المثل أو أقل، عملًا بعموم قوله تعالى: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» ، وإذا كان البيع بأقل من ثمن المثل بكثير صح إذا عرف العاقدان الثمن الحقيقي ورضيا، لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ» ، قال القرطبي: اعلم أن كل معاوضة تجارة على أي وجه كان العوض إلا أن قوله تعالى «بِالْبَاطِلِ» أخرج

منها كل عوض لا يجوز شرعًا من ربا أو جهالة أو تقدير عوض فاسد، والجمهور على جواز الغبن في التجارة وأن المالك الصحيح الملك جائز له أن يبيع ماله الكثير بالتافه اليسير إذا عرف قدر ذلك، وأما من باع وهو غير بصير بقيمتها فقد ذهب جمهور الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه لا خيار له بالغبن، بينما المشهور من قول المالكية والحنابلة أن له القيام بالغبن غير المعتاد وحدوده الثلث.

تصوير المسألة وتكييفها: وبالنظر لصورة الإجارة المنتهية بالتمليك بثمن رمزي نجد أنها اشتملت على عقدين: إجارة ناجزة تم فيها تحديد ثمن المنفعة والمدة وتوزيع الثمن على أقساط معلومة، وبيع معلق على شرط سداد أقساط الإجارة في المدة المحددة؛ ولما كان الثمن الرمزي ليس الثمن الحقيقي للسلعة وإنما هو جزء منه وباقي الثمن هو الأقساط الإيجارية، وإرادة المتعاقدين تتجه إلى البيع، فهي نفس الصورة السابقة إلا أنه تحدد ثمن رمزي للعين يدفعه المستأجر في نهاية المدة متى رغب في شرائها، **وكيفه فقهاء القانون على أنه بيع مقسط فيه الثمن، لكن الذي يمنع تكييفه بذلك في الفقه الإسلامي الصيغة وهي قول المالك «أجرتك»، فهذا اللفظ دال على الإجارة إلى انتهاء الأجل ثم عقد بيع بعد القيام بالالتزامات** .

الرأي:	البيان:
الأول:	**عدم الجواز** ، وإليه ذهب د. منذر قحف، ود. حسن الشاذلي، وبه أخذ غالب هيئة كبار العلماء في السعودية ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
الثاني:	**الصحة بشروط** ، وبه قال الشيخ عبد الله بن منيع، ود. محمد مختار السلامي، ود. وهبة الزحيلي، والهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية، والهيئة الشرعية في مجموعة دلة البركة.

دليل المنع: حديث: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» ، ووجه الدلالة أنهما عقدان وردا على عين واحدة غير مستقر على أحدهما، ولأن العقد فيه جهالة وغرر إذ عقد البيع معلق على تمام سداد أقساط الإجارة ومدة الإجارة قد تكون طويلة تتغير فيها السلعة فتكون العين مجهولة الصفة وهذا مما يبطل البيع.

دليل الجواز: أن الأجرة والثمن كما يجوز أن يكونا أقل من المثل فكذلك يجوز أن يكونا أكثر، والعبرة تراضي العاقدين واتفاقهما على المقدار وألا يكون تغرير وخداع، ولأنه لا حجر على الرشيد العالم في الثمن الذي يرضى به خاصة إذا كان البائع بنكًا له خبراؤه

شروط المجيزين: اشترط د. محمد مختار السلامي تقديم الثمن الرمزي المتفق عليه حتى لا يؤول إلى تعمير ذمتين فيدفع حالًا أو يدفع الثمن المتفق عليه ناجزًا، وبه أفتت هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي: «وليس لبيت التمويل الكويتي أن يهب من أموال المؤسسين أو المستثمرين إلا بإذنهم، ولا أن يبيع السيارة بسعر رمزي»، ومن الشروط أن يكون عقد الإجارة حقيقيًا مستجمعًا لأركانه وشروطه، وأن يكون عقد البيع في أثناء مدة الإجارة أو بعد انتهائها حتى لا يجتمع عقدان في عقد واحد، وأن يكون التأمين تعاونيًا إسلاميًا يتحمله المالك، واشترط د. وهبة الزحيلي موافقة الجمعية العمومية أو أصحاب الصناديق على التصرف.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الثاني** ، القائل بصحة الإجارة المنتهية بتملك العين بثمن رمزي، على أن يكون عقد البيع منفصلًا عن عقد الإجارة، سواء كان في أثناء مدة الإجارة أو بعد انتهائها، مع مراعاة باقي الشروط.

- **قوة أدلة المجيزين:** لقوة أدلة المجيزين، من أن الأجرة والثمن كما يجوز أن يكونا أقل من المثل فكذلك يجوز أن يكونا أكثر، والعبرة تراضي العاقدين.
- **حقيقة الثمن الرمزي:** وخاصة أن الثمن الرمزي ليس الثمن الحقيقي المقدر للسلعة وإنما هو جزء منه والباقي من الثمن هو الأقساط المتفق عليها.

المسألة السابعة: حكم الصورة الثانية – التمليك بثمن حقيقي:

تصوير المسألة: في هذا العقد يتحدد الثمن الحقيقي للسلعة المؤجرة عند إبرام عقد الإجارة، أو يتفق المتعاقدان على تحديده بعد الانتهاء من دفع القسط الأخير خلال المدة المحددة، ويترتب على تحديده اختلاف في مقدار القسط، وبذلك يتحقق للبنك المؤجر عائد تمويلي مع أخذ الأقساط الإيجارية بعين الاعتبار؛ وفي هذا العقد ثمن المنفعة ممكن أن يكون مثليًّا أي يمثل ثمن الانتفاع بالعين في المدة المحددة فقط، وممكن أن يكون أكثر بقليل مما يجعل ثمن السلعة في نهاية الإجارة أقل من سعر السوق بقليل حافزًا للمستأجر لتنفيذ الوعد بالشراء.

التكييف والحكم: وتكييف هذا العقد أنه إجارة في بدايتها تسري عليها آثار الإجارة وأحكامها، وبعد الوفاء بكافة الأقساط يتملك المستأجر العين بعقد بيع بثمن حقيقي وتترتب عليه أحكام البيع وآثاره، وهذه الصورة **يمكن القول بصحتها في الفقه الإسلامي** ، وهو ما

قرره مجمع الفقه الإسلامي على أن تتضمن الإجارة وعدًا بالبيع من البنك المؤجر ووعدًا بالشراء من المستأجر.

المسألة الثامنة: الإجارة المقرونة بوعد بالبيع:

تصوير المسألة: هذه الصورة أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين في مقابل أجرة محددة في مدة محددة، على أن المؤجر يعد المستأجر وعدًا ملزمًا إذا وفى بسداد الأقساط في المدة المحددة ببيع العين في نهاية العقد بمبلغ معين.

التكييف الفقهي: لا يخرج عن كونه **عقد إجارة عادي خلال كامل مدة العقد** فيسري عليه جميع أحكام الإجارة إلى حين تمليك المستأجر العين فتنتقل صفته من مستأجر إلى مالك، وقد ورد هذا التكييف في فتوى ندوة البركة.

الحكم الشرعي: الحكم الشرعي يبنى على حكم الوفاء بالوعد، وقد سبق أن الراجح وجوب الوفاء ديانة إلا لعذر، وقضاء إذا كان معلقًا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة هذا الوعد؛ وبناءً عليه يكون الوعد الصادر من المالك المؤجر ببيع السلعة للمستأجر إذا رغب ودفع ثمنًا هو كذا وعدًا ملزمًا بعد تحقق الشرط وهو استيفاء جميع الأقساط وإبداء الرغبة وتقديم الثمن، أما إذا صدر الوعد منهما بأن وعد المالك بالبيع ووعد المستأجر بالشراء إذا تحقق الشرط وحدد الثمن فكل منهما ملزم بهذا الوعد ولكن بشرط وجود صيغة جديدة تصدر عند تحقق الشرط لعدم وجود صيغة له من قبل، أي **الجواز مشروط بأن يكون عقد البيع منفصلًا عن عقد الإجارة** .

النتيجة: **هذه الصورة بالضوابط المذكورة جائزة لعدم وجود المحظور الشرعي فيها** ، وهي من الصور التي أقرها مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض.

1. **الخطوة الأولى:** عقد شراء العين من المورد أو بتوكيل سابق مستقل للراغب في الاستئجار.
2. **الخطوة الثانية:** ويبرم عقد إجارة بشكله المستقل.
3. **الخطوة الثالثة:** وبشكل متوازٍ مع إبرام عقد الإجارة يتم اتفاق الطرفين على كيفية نقل ملكية العين للمستأجر في نهاية الإجارة بوثيقة مستقلة، سواء كان بعقد الهبة المعلق أو بالوعد بالبيع بالسعر الرمزي أو السعر المتفق عليه.

٤ **الخطوة الرابعة:** وتنفيذ عملية نقل الملكية بإيجاب وقبول يصدر من الطرفين في حالة وثيقة عقد الإجارة إذا اشتملت على وعد ببيع الأعيان المؤجرة.

المسألة التاسعة: الإجارة المنتهية بالهبة:

صورتاها: الأولى: أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين في مقابل أجرة محددة في مدة محددة، على أن المؤجر يعد وعدًا ملزمًا بهبة العين للمستأجر إذا وفى بسداد الأقساط في المدة المحددة في نهاية العقد، الثانية: أن يصاغ العقد على أساس أنه عقد إجارة مع عقد هبة فوري معلق على شرط سداد جميع الأقساط، كأن يقول: إذا قمت بسداد جميع الأقساط المتفق عليها في المدة المحددة فإني وهبتك هذه الدار، ووافق الطرف الآخر.

١ الحكم في الصورة الأولى:

الحكم: يدخل تحت حكم لزوم الوعد أو عدم لزومه؛ وبناء على الراجح من لزوم الوفاء بالوعد ديانة إلا لعذر وقضاء إذا دخل الموعود بسببه في كلفة، وفق الضوابط المذكورة في الصور السابقة، فهذه الصورة **جائزة لعدم وجود المحظور الشرعي فيها** ، وهذا من الصور التي أقرها مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرة.

فتوى ندوة بيت التمويل الكويتي ١٩٨١م: إذا وقع التعاقد بين مالك ومستأجر على أن ينتفع المستأجر بمحل العقد بأجرة محددة بأقساط موزعة على مدد معلومة على أن ينتهي هذا العقد بملك المستأجر للمحل، فإن هذا العقد **يصح** إذ روعي فيه ما يأتي: ضبط مدة الإجارة وتطبيق أحكامها طيلة تلك المدة، وتحديد مبلغ كل قسط من أقساط الأجرة، ونقل الملكية إلى المستأجر في نهاية المدة بواسطة هبتها إليه تنفيذًا لوعد سابق بذلك بين المالك والمستأجر، على أن يكون بإيجاب وقبول يصدر من الطرفين في حالة وثيقة وعد بالهبة.

٢ الحكم في الصورة الثانية:

البيان وسبب الخلاف: هذه الصورة يدخل حكمها تحت اختلاف الفقهاء في حكم تعليق الهبة على شرط مستقبل، والسبب في الخلاف: هل الهبة من عقود التمليكات التي يجب أن تكون منجزة فلا تقبل التعليق؟ أم هي من عقود التبرعات التي يتفضل بها المتبرع كيف شاء فيصح تعليقها كالوصية؟ وقد اختلف فقهاء السلف في ذلك على رأيين.

الرأي:	البيان:
الأول:	**عدم جواز تعليق الهبة على شرط مستقبل** ، وهو قول جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، ووافقهم الظاهرية؛ ودليله أن الأصل في عقود التمليكات أن تكون منجزة، جاء في المغني: «ولا يصح تعليق الهبة بشرط؛ لأنها تمليك لمعين في الحياة، فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع».
الثاني:	**جواز تعليق الهبة على شرط مستقبل** ، وهو قول بعض الحنفية والمالكية، ورواية لأحمد، وهو ما قال به شيخ الإسلام ابن القيم.

حديث أم كلثوم بنت أبي سلمة: قالت: لما تزوج رسول الله ﷺ أم سلمة قال لها: «إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأَوَاقِيَّ مِنْ مِسْكٍ، وَلَا أَرَى النَّجَاشِيَّ إِلَّا قَدْ مَاتَ، وَلَا أَرَى إِلَّا هَدِيَّتِي مَرْدُودَةً عَلَيَّ، فَإِنْ رُدَّتْ عَلَيَّ فَهِيَ لَكِ» ، قال: وكان كما قال رسول الله ﷺ، وردت عليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة.

حديث جابر: قال: قال لي النبي ﷺ: «لَوْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا ثَلَاثًا» ، فلم يقدم حتى توفي النبي ﷺ، فأمر أبو بكر مناديًا فنادى: من كان له عند النبي ﷺ عدة أو دين فليأتنا، فأتيته فقلت: إن النبي ﷺ وعدني، فحثى لي عدة ثلاثًا؛ ووجه الدلالة صحة تعليق الهبة على شرط.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الثاني** ، القائل بجواز تعليق الهبة على شرط مستقبل.

قوة الأدلة: لقوة أدلة أصحاب الرأي الثاني حيث استدلوا بالسنة في حديث أم كلثوم وحديث جابر.

طبيعة الهبة: ولأن الهبة من عقود التبرعات والمتبرع متفضل فله أن يتبرع كيفما شاء.

> **كلمة ابن القيم:** قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: «فما الدليل على بطلان تعليق الهبة بالشرط، وقد صح عن النبي ﷺ أنه علق الهبة بالشرط»، ثم ذكر الحديثين، ثم قال: «فالصحيح صحة تعليق الهبة بالشرط عملًا بهذين الحديثين».

النتيجة: وبناء على ذلك ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى **جواز هذه الصورة** ، وهي أن تشتمل صيغة الإجارة على هبة السلعة بعد انتهاء مدة الإجارة وسداد الأجرة المتفق عليها ويقبل الطرف الآخر فتكون هبة معلقة على شرط، وهي من الصور التي أجازها مجمع الفقه الإسلامي.

5 قرار المجمع وضوابط الصور الجائزة:

قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي – الدورة الثانية عشرة بالرياض: جاء في قرار الإيجار المنتهي بالتمليك: أولًا: ضابط الصور الجائزة والممنوعة: أ. **ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد** ، ب. **ضابط الجواز: وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانًا** بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة والخيار يوازي الوعد في الأحكام.

- **الإجارة فعلية:** أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.
- **الضمان على المالك:** أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعد المستأجر أو تفريطه ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.
- **التأمين تعاوني:** إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيًا إسلاميًا لا تجاريًا ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.
- **تطبيق الأحكام بحسب العقد:** يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين.
- **الصيانة غير التشغيلية:** وتكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر طوال مدة الإجارة.

قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الصيانة – الدورة الحادية عشرة بالمنامة: الصيانة المشروطة في عقد الإجارة على المؤجر أو المستأجر، هذا عقد اجتمع فيه إجارة وشرط، وحكم هذه الصورة أن **الصيانة إذا كانت من النوع الذي يتوقف عليه استيفاء المنفعة فإنها تلزم مالك العين المؤجرة من غير شرط ولا يجوز اشتراطها على المستأجر** ، أما الصيانة التي لا يتوقف عليها استيفاء المنفعة فيجوز اشتراطها على أي من المؤجر أو المستأجر إذا عينت تعيينًا نافيًا للجهالة.

6 أهم النتائج والضوابط:

النتيجة العامة: الإجارة المنتهية بالتمليك تعد من العقود التي توفر التمويل اللازم للحصول على الاحتياجات الرأسمالية التي تتلاءم مع حجم النشاط للأفراد والشركات، ولها مزايا للمؤجر والمستأجر تنعكس على الاقتصاد الوطني إذا تمت وفق الضوابط الشرعية.

- **الإجارة حقيقية:** أن يكون عقد الإجارة عقدًا حقيقيًا مستجمعًا لأركانه وشروطه، ومن ذلك العلم بالأجرة وتحديد مدة الإجارة وأن تكون العين صالحة للإجارة، بحيث يترتب على عقد الإجارة جميع آثاره المقررة شرعًا للمؤجر والمستأجر مع الوعد بالتمليك بعد انتهاء مدة الإجارة.
- **يد المستأجر:** أن تكون يد المستأجر على الأصل يد منفعة أي يد أمانة، وإذا اشتمل العقد على تأمين فيجب أن يكون تعاونيًا إسلاميًا لا تجاريًا ويتحمله المالك المؤجر.
- **الأجرة ثمن المنفعة:** والأجرة المدفوعة أثناء مدة الإجارة تعتبر ثمنًا للمنفعة التي استوفاها المستأجر ومن ثم لا يجوز له المطالبة باستردادها إذا لم يتحقق الوعد بالتملك.
- **نفقات التشغيل:** ويتحمل المستأجر النفقات الخاصة بالتشغيل.
- **انتقال الملكية:** ولا تنقل ملكية الأصل المؤجر للمستأجر إلا بعد وفائه بالتزاماته المتمثلة في الأقساط المتفق عليها.
- **انفصال العقدين:** وأن يكون عقد البيع في أثناء مدة الإجارة أو بعد انتهاء مدتها حتى لا يجتمع عقدان في عقد واحد.
- **طريقة نقل الملكية:** ويتم نقل ملكية الأصل إلى المستأجر إما بعقد هبة منفصل عن عقد الإجارة وإما بعقد بيع، وفي الحالتين يكون هناك وعد بالهبة أو البيع عند إبرام عقد الإيجار، والوعد بالبيع أو بالهبة من الصور التي أجازها مجلس مجمع الفقه الإسلامي.

MARA 01054054178

أحكام المناقصات في الفقه الإسلامي:

١ مفهوم المناقصة وإجراءاتها وأسسها وأنواعها

٢ التكييف الفقهي وحكم بيع المزايدة

٣ البيوع المنهي عنها وحكم بيع كراسة الشروط

٤ الضمان وحكم العجز عن التنفيذ

١ مفهوم المناقصة:

المناقصة لغةً: من النقص، وهو عكس المزايدة، وهي تنافس في عرض أقل الأسعار، فيقع الالتزام على من قدّم أحسن الشروط من ناحية الخدمة المطلوبة وأرخص الأسعار.

المناقصة اصطلاحًا: من العقود الحديثة التي لم يجد لها الباحثون تعريفًا في كتب الفقهاء القدامى، وقد عرّفها بعض المعاصرين بأنها: **إجراء بمقتضاه تلتزم الجهة المعلنة عنه بالتعاقد مع صاحب عرض العوض الأقل من عروض المتنافسين للفوز فيه، نظير الوفاء بما التزم به مطابقًا للشروط والمواصفات المقررة** .

1. **تحليل لفظ «إجراء»:** يشمل كل إجراء تعاقدي أو غير تعاقدي، فيدخل فيه ما كان بعقد وما كان بمجرد إعلان.
2. **تحليل لفظ «تلتزم الجهة المعلنة»:** يبين أحد أركانها، ويخرج كل إجراء لا يتضمن التزامًا؛ لأنه لا يكون مناقصة معتبرة شرعًا وعرفًا.
3. **تحليل لفظ «بالتعاقد»:** يخرج الالتزام المستقل عن إرادة الغير؛ لأن العقد ارتباط بين إرادتين، فلا بد من قبول من صاحب العطاء الأقل.
4. **تحليل لفظ «صاحب عرض العوض الأقل»:** يخرج عقد المزايدة، ويعد ركنًا من أركانها؛ لأن المزايدة تعتمد على أعلى سعر لا الأقل.
5. **تحليل لفظ «نظير الوفاء بما التزم به مطابقًا للشروط»:** يبين أن العوض مقابل التزام مطابق للشروط، سواء كان توريدًا أو مقاولة أو غير ذلك.

الفرق بين المناقصة والمزايدة والشراء المباشر: **المزايدة** يجريها البائعون ليعقدوا البيع بأعلى سعر، و **المناقصة** ترغب فيها الجهة الداعية بأقل سعر؛ وتختلف عن الشراء

المباشر لأن لها إجراءات تسبقها وتمهد لها.

2 إجراءات المناقصات:

1. **التقدير والاعتماد:** عندما تحتاج جهة إدارية إلى سلع للتوريد أو أعمال للتنفيذ فإنها تقدّر القيمة التقريبية وتتأكد من الاعتماد اللازم للموازنة.
2. **لجنة المواصفات والشروط:** تشكّل لجنة لوضع المواصفات والشروط، مثل شرط التسليم في محل البائع أو ميناء الشحن أو ميناء الوصول أو مستودعات الجهة الإدارية؛ لأن هذه الشروط تؤثر في الثمن وتحديد من يتحمل المصاريف.
3. **الدعوة إلى المناقصة:** تجرى الدعوة عن طريق الإعلان في الصحف الكثيرة الانتشار إذا كانت عامة، ويحدد فيه الصنف أو العمل المطلوب وقيمة دفتر الشروط وآخر موعد لتقديم العروض، مع اشتراط شراء دفتر الشروط للاشتراك، ويحتوي على المعلومات التي أعدتها الجهة الإدارية.
4. **تقديم العروض:** بعد الحصول على الدفتر يدرسه الراغبون، فإذا وجدوا القدرة والرغبة تقدموا بعروضهم في مظاريف مختومة بالشمع الأحمر وموقعة لا تفتح إلا في الموعد المحدد، وليس للمناقصين بعد تقديم عروضهم تعديل الأسعار بالزيادة أو النقصان؛ لما في ذلك من الإخلال بمبدأ المساواة والسرية.
5. **لجان الفتح والفحص والبث:** ثم تشكّل لجنة لفتح المظاريف بعد التأكد من سلامة الأختام بحضور المناقصين أو مندوبيهم، ولجنة لفحص العروض والتأكد من الشروط الشكلية ومطابقتها للمواصفات، ثم لجنة للبت في العروض التي توافرت فيها الشروط كتقديم الضمان الابتدائي وصورة السجل التجاري وبطاقة الغرفة التجارية، فتختار العرض الأقل سعرًا وتعد محضرًا توصي بقبوله وأسبابه.

3 الأسس التي تقوم عليها المناقصات:

1. **المنافسة:** يراد بها إتاحة الفرصة لكل من تتوافر فيه شروط المناقصة أن يتقدم بعطائه، حتى يكون المجال مفتوحًا للإدارة في اختيار من تراه مناسبًا، ويتطلب ذلك الإعلان عن المناقصة فلا تستطيع الإدارة منع أحد من التقدم ما دام استوفى الشروط؛ ومن فوائد الإعلان تجنب أجواء الشك والريبة، وإيجاد منافسة مشروعة تؤدي إلى اختيار أفضل العقود، وتأكيد مبدأ حرية التجارة والعمل والمساواة بين الأفراد.

2 **المساواة:** وهي من أهم الأسس، وتتجلى في الإعلان حتى يعلم به أكبر عدد ممكن في صحف واسعة الانتشار، وتجنب ذكر مواصفات تنطبق على بلد أو مورد بعينه، ومنح الجميع مهلة كافية، وعدم تعديل الشروط لمصلحة أحد المناقصين وعدم استبعاد العطاءات بقرارات عامة أو فردية وأن تكون معايير القبول والاستبعاد واحدة للجميع، وعدم العدول عن التعاقد مع صاحب العطاء الأقل إلا بقرار مسبب، والمساواة في المعلومات والفرص واحترام المواعيد وإجراءات التسليم والصرف والضمان، وفي حالة التساوي يلجأ إلى التفاوض فإن بقي التساوي قسمت الكمية إن أمكن وإلا اختير أحدهما بالقرعة، ووجود رقابة فعالة لمنع التجاوزات والمحاباة والرشوة وإفشاء السرية.

4 أطراف المناقصة وأنواعها:

الطرف:	البيان:
الجهة الإدارية:	صاحبة المناقصة التي تطرحها وتعلن عنها، وقد تكون مصلحة حكومية أو شركة.
الموردون أو المقاولون:	المشتركون الذين يتنافسون للفوز بالتعاقد بأقل عطاء.

باعتبار نظامها: عامة وهي الأصل توجه الدعوة فيها لعدد غير محدود وتخضع لمبدأ العلانية وتكافؤ الفرص ويعلن عنها في الصحف الرسمية، ومحدودة توجه الدعوة فيها إلى عدد محدود بالرسائل ممن تتوافر فيهم الأهلية المالية والفنية وحسن السمعة ويلجأ إليها استثناءً لتحقيق مصلحة مالية عامة، ولا فرق بين النوعين شرعًا.

باعتبار حدودها: داخلية يقتصر الاشتراك فيها على من هم داخل البلد، وخارجية يشترك فيها موردون من خارجه.

باعتبار طرق إجرائها: علنية يحضر المناقصون ويقدمون عروضهم بصورة علنية ويتناقصون في السعر حتى ترسو على صاحب السعر الأقل، وسرية وهي السائدة حديثًا، والواضح أن العلنية تحقق الغرض وهو التنافس للوصول إلى أفضل عرض، أما سرية المناقصات الحديثة فلأنها مناقصات فنية معقدة تحتاج إلى دراسة وقد تنطوي على كميات كبيرة وقد يخشى في العلانية أن يندفع البعض إلى أسعار غير معقولة فيتعثر التوريد أو التنفيذ.

باعتبار موضوعها: مناقصات موضوعها الشراء حين تحتاج إدارة إلى شراء ما تحتاجه بمواصفات معينة فتسعى إلى أقل الأسعار، ومناقصات موضوعها الإجارة وتتعلق بإجارة أشياء تستعين بها الإدارة، ومناقصات لأجل الاستثمار كما في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة.

المسألة الأولى: التكييف الفقهي للمناقصات:

البيان وسبب الخلاف: المناقصة عقد حديث لم يعرفه الفقهاء القدامى بهذا الاسم، فمن ثم كان لا بد من البحث في تكييفه: هل هو من العقود المسماة في الفقه فيخرج عليها؟ أم هو عقد مستحدث لا شبيه له؟ والسبب في الخلاف يرجع إلى أن المناقصة تشتمل على إجراءات متعددة وعقود متداخلة، فينظر بعضهم إلى مجموعها فيُخرجها على عقد واحد، وينظر آخرون إلى تعدد مراحلها فيُخرجها على منظومة عقود، وينظر ثالث إلى أن جوهرها هو العقد النهائي الذي تسفر عنه، فتكون المناقصة في نظره مجرد إجراءات للدخول في ذلك العقد، وعلى هذا التصور جاءت خمسة آراء.

الرأي:	البيان:
الأول:	**المناقصة كالمزايدة** ، ينطبق عليها ما ينطبق على المزايدة والاختلاف بينهما في الشكل فقط حتى إن معظم أحكامهما تنظمها لائحة واحدة؛ وبه قال د. رفيق المصري في قول له، ود. علي السالوس، ود. عبد الوهاب أبو سليمان، ود. محمد المختار السلامي.
الثاني:	**المناقصة تشبه عقد المسابقة في الاسم والمضمون** ، وبه قال د. رفيق المصري في قول ثانٍ له؛ فالمناقصة مسابقة بين المناقصين على الفوز بعقد التوريد أو المقاولة، ويشترط فيها ما يشترط في المسابقة من المساواة في المعلومات والفرص وسائر الشروط والمواصفات.
الثالث:	**المناقصات تختلف باختلاف موضوعها** ، والدعوة إلى المناقصة في أي عقد يجوز إنجازه شرعًا على الفور هي دعوة إلى هذه العقود؛ وهو ما قال به د. تقي العثماني، ويوافقه الشيخ حسن الجواهري.
الرابع:	**المناقصة منظومة عقود** ، يدخل فيها عدة عقود؛ لاشتمالها على عقد بيع دفتر الشروط وعقد الضمان بنوعيه ثم تنتهي بإبرام عقد يؤول إلى توريد سلع أو مقاولة خدمات، وهذا العقد المركب الإيجاب فيه يصدر من المناقص عند

تقديمه العطاء وهو ملزم له، والقبول فيه يصدر من المناقص له عند إبرامه العقد مع صاحب العطاء الأقل؛ وهو ما قال به رفيق المصري في قول له.

الخامس: **المناقصة ما هي إلا إجراءات للدخول في العقد وليست عقدًا** ، وبه قال الشيخ عبد الله بن منيع، ود، القره داغي، وغيرهما.

دليل الرأي الثالث: أن الدعوة إلى المناقصة في أي عقد يجوز إنجازه شرعًا على الفور هي دعوة إلى هذه العقود؛ فإن كان موضوعها عقد البيع أو الإجارة أو الاستصناع أو المقاولة فالدعوة إليها دعوة إلى هذه العقود، قال الشيخ حسن الجواهري: إن المناقصة من مصاديق البيع والتجارة وهي مشروعة؛ لقوله تعالى: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» ، وقوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، ووجه الدلالة أن المعاملة الجارية بصورة المناقصة هي بيع أو إجارة أو مزارعة أو مضاربة، فالدليل الذي دل على صحة هذه العقود هو نفسه الدليل على صحة المناقصة بشرط سلامة أصول العقد وتحقق أغراضه؛ ولأن المناقصات تستهدف المحافظة على المنافسة الشريفة في خفض الأسعار لصالح طالب السلعة أو خفض الأجرة لصالح طالب العمل، وقد يتعين ذلك إذا كان الغرض الشراء للأيتام بواسطة الحكام أو الوصي لما فيه من توقع الشراء بأقل ودفع التهمة، كما قد يتعين في الشراء لمؤسسات الدولة كالأوقاف، وإن لم يتعين فلا أقل من استحبابه.

مناقشة الرأي الثالث: بأن هذا التكييف لا يستقيم؛ لأن المراد تكييف المناقصة من حيث هي ذات المناقصة القائمة على اختيار صاحب العطاء الأقل وفق إجراءات معينة، لا تكييف ما تؤول إليه.

مناقشة الرأي الخامس: بأن المناقصة ليست إجراءات فقط بل هي عقد تام، إذ تقديم المناقص العرض يعد إيجابًا ملزمًا له لا يرجع عنه حتى ترسو المناقصة على غيره، وإبرام العقد بعد رسوها قبول، وتنتهي المناقصة بإبرام العقد بين المناقص له والمناقص صاحب العطاء الأقل، وهذا هو القبول الموافق للإيجاب السابق وهما من أركان العقد.

الراجح: **الراجح والله أعلم** أن أقرب التخريجات الفقهية للمناقصة أنها تشبه عقد المزايدة في كثير من الإجراءات مع مراعاة التقابل بينهما، وأنها منظومة عقود وليست عقدًا

واحدًا، مثل عقد بيع كراسة الشروط وعقد الضمان والعقد المتعلق بموضوع المناقصة كعقد توريد سلع وهو عقد بيع أو بيع منفعة أو عقد استصناع.

- **شبه المزايدة:** لأن المناقصة تشبه عقد المزايدة في كثير من الإجراءات مع مراعاة التقابل بينهما في أعلى السعر وأقل السعر.
- **تعدد العقود:** ولأن المناقصة منظومة عقود وليست عقدًا واحدًا، فتتضمن عقد بيع كراسة الشروط وعقد الضمان والعقد المتعلق بموضوع المناقصة.
- **الحكم الشرعي للأصل:** وكل عقد من هذه العقود له تكييفه الخاص وحكمه الشرعي، فتبقى المناقصة على أصل الإباحة ما لم يعترها محذور شرعي.

المسألة الثانية: حكم بيع المزايدة:

البيان وسبب الخلاف: لا يمكن الحكم على المناقصة دون بيان حكم بيع المزايدة؛ لأن المناقصة تقوم على مبدأ المنافسة في أقل سعر، والمزايدة تقوم على مبدأ المنافسة في أعلى سعر، فحكم إحداهما ينعكس على الأخرى، وبيع المزاد لغةً: البيع الذي يتم بطريق الدعوة إلى شراء الشيء المعروض ليرسو على من يعرض أعلى ثمن، واصطلاحًا عرّفها ابن حزم بقوله: «أن ينادي على السلعة ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض حتى تقف على آخر زائد فيها فيأخذها»، وعرّفها الزيلعي بقوله: «أن يظهر من البائع ما يدل على عدم الرضا بالبيع، فيأتي آخر فيزيد عليه»، والسبب في الخلاف يرجع إلى اختلاف النصوص الواردة في الباب بين ما يدل على الجواز فعلًا وقولًا، وما يدل على النهي؛ فمن غلّب جانب الجواز أجاز، ومن غلّب النهي منع، ومن حمل النهي على التنزيه كره.

الرأي:	البيان:
الأول:	**جوازه مطلقًا** ، وهو قول جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ووافقهم الظاهرية والزيدية.
الثاني:	**عدم جوازه إلا فيما يحصل عليه عن طريق الميراث والغنيمة** ، وهو قول الأوزاعي وإسحاق بن راهويه.
الثالث:	**كراهة بيع المزايدة** ، وهو قول إبراهيم النخعي.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة من السنة والأثر والإجماع والمعقول.

حديث جابر: أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي ﷺ فقال: «من يشتريه مني؟» فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه، وجه الدلالة: ظاهر الحديث يدل على جواز بيع المزايدة، ونوقش: بأنه ليس في قصة المدبر بيع مزايدة؛ فإن بيع المزايدة أن يعطي به واحد ثمنًا ثم يعطي به غيره زيادة عليها، وأجاب ابن بطال: بأن شاهد الترجمة منه قوله: «من يشتريه مني» ، فعرضه للزيادة ليستقصى فيه للمفلس الذي باعه عليه.

حديث أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ باع حلسًا وقدحًا وقال: «من يشتري هذا الحلس والقدح؟» فقال رجل: خذتهما بدرهم، فقال النبي ﷺ: «من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟» فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه، وجه الدلالة: ظاهر قوله «من يزيد على درهم» يدل على جواز بيع المزايدة إذ لم يجب من أعطى درهمًا.

أثر مجاهد وعطاء: روى ابن أبي شيبة عن سفيان عمن سمع مجاهدًا وعطاءً قالا: «لا بأس من بيع من يزيد».

الإجماع: نقله ابن قدامة في المغني قال: «وهذا أيضًا إجماع المسلمين، يبيعون في أسواقهم بالمزايدة».

المعقول: أن الحاجة ماسة إليه فهو بيع الفقراء والمحتاجين ومن كسدت تجارته، ولو ترك الناس الزيادة لدخل الضرر على الباعة، وقال الإمام مالك في تقييد النهي عن السوم على السوم بكونه بعد رضا المتعاقدين: «أما قبل التراكـن والتقارب فجائز؛ لأنه لو ترك ذلك لدخل الضرر على الباعة في سلعهم؛ لأنه يؤدي إلى بخسها وبيعها بالنقص».

أدلة الرأي الثاني ومناقشاتها: استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة من السنة والأثر، ونوقشت.

NARA 01054054

أثر ابن عمر: روى ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن أسلم قال: سمعت رجلًا سأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة فقال ابن عمر: «نهى رسول الله ﷺ أن يبيع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث» ، وجه الدلالة: ظاهره النهي عن بيع المزايدة إلا في الغنائم والمواريث، وهو مخصص لعموم حديث الجواز.

أثر الحسن وابن سيرين: روى ابن أبي شيبة عن الحسن وابن سيرين: «أنهما كرها بيع من يزيد إلا بيع المواريث والغنائم»، وروى ابن أبي شيبة عن المغيرة بن شعبة: «أنه باع المغانم فيمن يزيد».

مناقشة ذلك: من وجهين: أن ذكر المغانم والمواريث ليس قيدًا وذكرهما خرج مخرج الغالب ويلتحق بهما غيرهما للاشتراك في الحكم، وأن حديث ابن لهيعة في إسناده ضعف.

أدلة الرأي الثالث ومناقشاتها: استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة من السنة، ونوقشت.

حديث أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «لا يسم المسلم على سوم أخيه» ، وجه الدلالة: ظاهره النهي عن السوم في البيع، والسوم الزيادة.

مناقشة ذلك: بأن المراد النهي عن السوم بعد رضا البائع وقبوله الثمن، أما السوم في السلعة التي تباع لمن يزيد فلا يحرم.

حديث سفيان بن وهب: قال: سمعت النبي ﷺ: «لا ينهى عن المزايدة» ، وجه الدلالة: ظاهره النهي عن بيع المزايدة، والنهي يحمل على الكراهة لما قد يسببه من إثارة الحقد والبغضاء، كما يعارضه ما ورد عنه ﷺ قولًا وفعلًا في حديث أنس السابق.

الترجيح: الراجح والله أعلم هو الجواز ؛ لقوة أدلته، ولتعلق حاجة الناس بهذا النوع من البيوع في معاملاتهم دون التقييد بكون المبيع من ميراث أو غنيمة.

قوة الأدلة: لقوة أدلة الجواز من السنة والأثر والإجماع والمعقول، وظهورها في إثبات المطلوب.

تعلق حاجة الناس به: ولتعلق حاجة الناس بهذا النوع من البيوع في معاملاتهم، فلو ترك الناس الزيادة لدخل الضرر على الباعة.

عدم التقييد بالميراث والغنيمة: ولأن حديث الجواز لم يقيد بكون المبيع من ميراث أو غنيمة، فالتقييد المذكور لا دليل عليه، وحديث ابن لهيعة في إسناده ضعف.

المسألة الثالثة: البيوع المنهي عنها التي تلتبس بالمناقصات:

البيان وسبب الخلاف: ما يتم في المناقصة طبقًا لمبدأ المساواة أن ينقص المناقص عن الشخص الذي ناقص قبله، فمن ثم كان لا بد من بيان حكم البيوع المنهي عنها التي قد تلتبس بالمناقصات، وهي ثلاثة: بيع الرجل على بيع أخيه، والسوم على السوم، والنجش، والسبب في البحث هو بيان الفرق بين المناقصة وهذه البيوع؛ لأن المناقصة قد تشتبه بها في الصورة، فيظن بعض الناس دخولها تحت النهي، والحقيقة أن المناقصة متميزة عنها بضوابطها الخاصة، فيأتي بيان ذلك في كل مسألة.

١ بيع الرجل على بيع أخيه:

معناه وحكمه: معناه: أن يتراضى البائع والمشتري على ثمن سلعة فيجيء آخر في زمن الخيارين فيقول للمشتري: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأنقص من هذا الثمن فيضر بصاحب السلعة، أو يقول: أنا أبيعك خيرًا منها بثمنها، أو يعرض عليه سلعة يرغب فيها المشتري فيفسخ البيع ويشتري هذه؛ وفي معناه الشراء على الشراء، وحكمه: **يحرم عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة**، ووافقهم الظاهرية، بينما ذهب الحنفية إلى أنه **مكروه تحريمًا**؛ واستدلوا بما روي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «لا يبيع بعضكم على بيع أخيه».

الرأي:	البيان:
الأول:	**صحة بيع الرجل على بيع غيره مع لحوق المشتري الإثم**، وهو قول جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية في قول والشافعية والحنابلة في رواية، ووافقهم الزيدية، وهو الراجح؛ لأنه عقد مكتمل الأركان والشروط والنهي لأمر خارج عن عقد البيع.
الثاني:	**بطلان بيع الرجل على بيع أخيه**، وهو قول ثانٍ للمالكية وظاهر مذهب الحنابلة، ووافقهم الظاهرية؛ لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد.

شروط تطبيق المنع: يشترط لتطبيق المنع أربعة شروط: **أن يقع البيع من غير إذن البائع أو الشراء من غير إذن المشتري** فلو أذن المتضرر لم يحرم؛ و **أن يقع البيع مع رضا المتعاقدين على الثمن** بخلاف ما إذا لم يركن أحدهما إلى الآخر فهو بيع من يزيد وهو جائز؛ و **أن يقع البيع على البيع قبل اللزوم** أي في زمن خيار المجلس وخيار الشرط لتمكنه من الفسخ فإذا وقع بعد اللزوم فلا حرمة؛ وأضاف بعض الشافعية أن لا يكون المشتري مغبونًا غبنًا فاحشًا وإلا جاز البيع على البيع.

الفرق بين المناقصة والبيع على البيع: **أن الشروط التي وضعها الفقهاء لمنع البيع على البيع لم تتوافر في المناقصة** ؛ لأن الراغب في الاشتراك يتقدم بعطائه وليس معنى تقدمه بالعطاء الموافقة عليه من الطرف الآخر، ولم يحصل ركون أو ميل من الطرف الآخر لإبرام العقد، فلا تدخل المناقصة تحت النهي.

٢ السوم على السوم:

معناه وحكمه والحكمة منه: السوم هو الذهاب في ابتغاء الشيء، والتساوم بين اثنين أن يعرض البائع سلعته بثمن ما ويطلبها المشتري بثمن دونه، والسوم على السوم معناه: أن يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه فيقول آخر لصاحبها: أنا أشتريها بأكثر، أو للراغب: أنا أبيعك خيرًا منها بأرخص، وهذا حرام بعد استقرار الثمن، والفرق بين البيع على البيع والسوم على السوم: في البيع على البيع تم العقد إلا أن بين المتعاقدين خيار شرط أو مجلس، أما في السوم على السوم فهو بعد الاتفاق وقبل العقد، وحكمه: **يحرم سوم الرجل على سوم أخيه عند جمهور الفقهاء** ما عدا الحنفية حيث ذهبوا إلى أنه مكروه تحريمًا. والحكمة في تحريمه: لما فيه من إخلال بالمروءة وإيغار للصدور وزرع للبغضاء وإثارة للنزاع والشحناء وإفساد للمجتمعات بقطع الصلات، مما يتنافى مع حرص الإسلام على تآلف المجتمعات.

شروط المنع: يشترط لتطبيق المنع ثلاثة شروط: **أن يكون سوم الغير بعد استقرار الثمن** ، و **أن يكون بعد حصول التراضي بين المتعاقدين أو ركون كل منهما إلى الآخر** ، و **عدم الإذن من المتضرر** فإن أذن البائع أو المشتري بالسوم لم يدخل تحت النهي.

الفرق بين المناقصة والسوم على السوم: في سوم الرجل على سوم أخيه ورد السوم الثاني بعد استقرار الثمن ورضا المتعاقدين ولم يبق إلا أن يأخذ العقد شكله الأخير، أما المناقصات **فهي قبل استقرار الثمن** ؛ إذ يتقدم الراغب بعطائه ولما لم يرتض الطرف الآخر بالعطاء أو يركن إليه ووجد الإذن من صاحب المناقصة بالسماح لمن يرغب في الاشتراك بالتقدم

بعطائه، اكتسبت المنافسة بالنقصان في العطاءات الجواز والصحة فلم تدخل تحت النهي عن السوم على السوم.

٣ النجش:

تعريفه وحكمه وأدلته: لغةً: الاستتار؛ لأنه يستر قصده ويخفيه، وشرعًا: أن يمدح السلعة ويطلبها بثمن ثم لا يشتريها لنفسه ولكن ليسمع غيره فيزيد في ثمنها؛ والناجش لا يريد شراء السلعة ويزيد فيها لينتفع البائع ويضر المشتري حيث يظن أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا وهي تساويه فيغتر بذلك، ومن صوره من يمدح سلعته ويطري في مدحها بالكذب ليغر غيره، وحكمه: **ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، ووافقهم الظاهرية والزيدية، إلى حرمة النجش** ، بينما ذهب الحنفية إلى أنه مكروه تحريمًا فيما لو بلغت السلعة قيمتها، أما إذا لم تبلغ قيمتها فلا كراهة لانتفاء الخداع والتدليس.

دليل الحرمة من الكتاب: «وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا» ، وجه الدلالة: قال القرطبي: أذية المؤمنين والمؤمنات هي أيضًا بالأفعال والأقوال القبيحة كالبهتان والتكذيب الفاحش المختلق، فتغرير المشتري أو الغير يدخل تحت عموم الآية.

دليل الحرمة من السنة: ما رواه ابن عمر قال: «نهى النبي ﷺ عن النجش» ، وجه الدلالة: منطوقه يدل على حرمة النجش.

الرأي:	البيان:
الأول:	**صحة البيع ولزومه وعصيان الناجش** ، وهو قول الحنفية ووجه للشافعية والمختار عند الإباضية.
الثاني:	**البيع صحيح ويثبت فيه الخيار للمشتري إذا كان بمواطأة البائع** ، وهو قول للمالكية ووجه خلاف الأصح عند الشافعية ورواية للحنابلة، ووافقهم الظاهرية والزيدية والإباضية في قول ثانٍ، وأضاف الحنابلة أن الخيار يثبت للمشتري إذا غبن غبنًا غير معتاد وإن لم يكن بمواطأة البائع.
الثالث:	**البيع باطل** ، وهو قول الإمام أحمد في رواية عنه.

أدلة الرأي الأول: حديث ابن عمر: «نهى النبي ﷺ عن النجش» ، والنهي عائد إلى الناجش لا إلى العقد فلم يفسد؛ لأن النهي المقتضي للفساد هو المتعلق بالعقد لا لأمر خارج، والنجش ليس عيبًا في نفس البيع وإنما خديعة في الثمن، ولأن المشتري زاد في الثمن عن اختياره وإرادته.

أدلة الرأي الثاني ومناقشتها: استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة من السنة والمعقول، ونوقشت.

حديث أبي هريرة في المصراة: قال رسول الله ﷺ: «من اشترى غنمًا مصراة فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر» ، وجه الدلالة: جعل الرسول ﷺ لمشتري المصراة الخيار إذا علم بعيب التصرية ولم يقض بفساد البيع، والنجش مثل التصرية لما فيه من مكر وخديعة، ونوقش: بأن النجش ليس عيبًا في نفس المبيع كالمصراة المدلس بها وإنما هو كالمدح، وكان يجب على المشتري التحفظ والاستعانة بأهل الخبرة.

من المعقول: أن في البيع مع النجش تغريرًا بالعاقد فإذا كان مغبونًا ثبت له الخيار كما في تلقي الركبان، وأن النهي لحق الآدمي وحق الآدمي يمكن جبره بالخيار.

أدلة الرأي الثالث: استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة من السنة والأثر.

حديث عائشة: أن رسول الله ﷺ قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» ، وجه الدلالة: ظاهره أن البيع مع الخديعة باطل مردود.

حديث ابن عمر: «نهى النبي ﷺ عن النجش» ، والنهي يقتضي الفساد.

أثر عمر بن عبد العزيز: روى ابن أبي شيبة أن عمر بن عبد العزيز بعث عمرة بن زيد الفلسطيني يبيع السبي فيمن يزيد، فلما فرغ جاءه فقال له عمر: كيف كان البيع اليوم؟ فقال: إن البيع كان كاسدًا يا أمير المؤمنين لولا أني كنت أزيد عليهم فأنفقه، فقال عمر: كنت تزيده عليهم ولا تريد أن تشتري؟ فقال: نعم، قال عمر: هذا نجش، والنجش لا يحل، ابعث يا عمرة مناديًا ينادي: ألا إن البيع مردود، وإن النجش لا يحل.

الترجيح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الثاني** ، القائل بصحة البيع مع ثبوت الخيار للمشتري، متى كان ذلك بمواطأة البائع ووقع البيع بأكثر من قيمته.

- **قوة الأدلة:** لقوة أدلة أصحاب هذا الرأي، وظهورها في إثبات الخيار للمشتري.
- **سلامة العقد:** ولأن النهي إنما ورد لأمر خارج عن العقد فهو عقد كامل الأركان والشروط، فلا يبطل.
- **جبر الغبن:** ويثبت الخيار للمشتري جبرًا للغبن الذي قد يقع فيه متى كان ذلك بمواطأة البائع ووقع البيع بأكثر من قيمته.
- **قاعدة لا ضرر ولا ضرار:** ولأنه ﷺ «قضى أن لا ضرر ولا ضرار» فيما رواه عنه عبادة بن الصامت، فيُجبر الضرر بالخيار.

الفرق بين المناقصة والنجش: أن صورة النجش قد توجد في المناقصة لكن معكوسة، كأن تتواطأ الجهة الإدارية مع أحد المشتركين بأن يتقدم بعطاء يعرض فيه ثمن أقل من ثمن السوق وهو غير مريد للبيع حقيقة وإنما خدمة للجهة؛ فالعلة التي نهي عن النجش لأجلها متحققة وهي الخديعة للغير والإضرار به، فلو تقدم أحد المشاركين بعرض فيه تنقيص في الثمن وهو لا يريد بيعًا لحق مقدم العطاء الإثم وإن لم يوجد تواطؤ من الطرف الآخر، **وعليه فإن المناقصة تشترك مع النجش في صورة تنقيص الثمن ولكنها تختلف عنه في انتفاء قصد البيع من الناجش** .

المسألة الرابعة: حكم بيع كراسة الشروط:

البيان وسبب الخلاف: المعمول به أن تصدر الجهة الإدارية كراسة الشروط وهي تشتمل على تفاصيل العقد ومواصفاته وتطرح للبيع عند الإعلان عن المناقصة؛ والعناصر المؤثرة في تكاليف إجراء المناقصة: المجهود الذهني في دراسة المشروع وإعداده، وتكاليف إعداد الخرائط والرسوم والمخططات، وتكاليف الخدمات والاستشارات الهندسية، وقيمة الأوراق المتعلقة بالمشروع، وحصة من المصاريف الإدارية، والسبب في الخلاف يرجع إلى التردد في تكييف كراسة الشروط: هل هي عين من الأعيان يجوز بيعها كسائر الأموال؟ أم هي مجرد بيان لشروط العقد من أحد العاقدين فلا يصح أخذ العوض عليه؟ أم هي وثيقة تحقق مصلحة مشتركة بين الجهة والمتنافسين فيتحملها من ظفر بالمناقصة؟ أم يُفرَّق بين ما إذا كانت مشتملة على دراسات فنية أم لا؟ وعلى هذا التصور جاءت أربعة آراء.

الرأي:	البيان:
الأول:	**جواز بيع كراسة الشروط لمن يرغب المشاركة** ، وهو ما ذهب إليه الشيخ مختار السلامي، ود، عبد الله المنيع، وأبو سليمان في قول ثانٍ له، والشيخ حسن الجواهري.
الثاني:	**الذي يتحمل قيمة كراسة الشروط هو المناقص الذي رست عليه المناقصة** ، وبه قال الشيخ عبد الوهاب أبو سليمان.
الثالث:	**وجوب بذل كراسة الشروط بالمجان** وعلى الجهة المصدرة أن تتحمل تكلفة إعداده، لكن يجوز أخذ تأمين من طالب الدفتر على أن يرد إليه إذا رد دفتر الشروط؛ لعدم اشتراكه في المناقصة أو لعدم رسوها عليه أو لإلغاء المناقصة، وهو قول د. رفيق المصري.
الرابع:	**جواز بيع كراسة الشروط إذا كانت مشتملة على دراسات فنية ورسم خرائط** على أن تكون القيمة تمثل قيمة تكاليف إعدادها، بخلاف ما لو كانت مشتملة على مجرد شروط العقد؛ لأنه بمنزلة بيان شروط العقد من أحد العاقدين، وهو قول د. محمد تقي العثماني.

أدلة الرأي الأول ومناقشاتها: استدل أصحاب هذا الرأي بأن كراسة الشروط تحتوي على معلومات يجوز بيعها لمن يريد اقتناءها للدخول في المناقصة، عملًا بعموم الأدلة الدالة على مشروعية البيع منها قوله تعالى: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» ، وقوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» ؛ وأن كراسة الشروط وثيقة مادية مسعرة بسعر محدد لم يلزم بها أي مشترٍ إلزامًا ظالمًا. ونوقش: بأن الأعيان والمنافع التافهة القيمة لا تعد من الأموال المتقومة مثل قطرة الماء وحبة القمح، ولكن هل ثمن دفتر الشروط من هذا القبيل؟ وأن قيمة كراسة الشروط تمثل قيمة ما أنفق على إعداده والغرض أن لا يدخل في المناقصة من ليس أهلًا لها فتضيع الفرصة ثم يرجع إلى الذي يليه، كما يبين جدية المناقص؛ ونوقش بأن الجدية تتعلق بالضمان لا بدفتر الشروط، وأن اشتراط الحصول على كراسة الشروط بثمن شرط سائغ ليس له تأثير في العقد، وأن من لم يرس عليه العطاء مستفيد أيضًا بمعرفة مدى إمكانية إنجازه للمطلوب فلا يدخل مغامرًا دون معرفة قدراته وإمكاناته مما يساعده على الفوز في مناقصات مستقبلية.

أدلة الرأي الثاني: أن ما تشتمل عليه كراسة الشروط من مواصفات ودراسات ستوفر على المتقدم الكثير بحيث لا يحتاج إلا للتنفيذ بموجبها عندما يرسو عليه العطاء، فإذا كان ذلك معلومًا لديه مسبقًا احتسب تكلفة تلك الدراسات ضمن تكاليف المشروع؛ وأن المناقصين الذين لم يرس عليهم العطاء يدفعون تلك الرسوم دون مقابل، والعدل والإنصاف يقضي أن تكون مسئولية دفع التكاليف جميعها على من ظفر بالمناقصة.

أدلة الرأي الثالث: أن الجهة المصدرة هي المستفيدة فهي التي اختارت إجراء المناقصة وحددت شروطها ومن له الغنم كان عليه الغرم؛ وأن المناقصين لو حملوا بثمن دفتر الشروط فإن واحدًا منهم فقط هو الذي سيفوز بالعقد وليس هناك وجه لتحميل سائر المناقصين تكلفة دفتر الشروط؛ وأن أخذ الجهة الداعية تأمينًا نقديًا إنما هو لحماية دفتر الشروط ممن يأخذه وهو غير جاد.

أدلة الرأي الرابع: أن كراسة الشروط إذا كانت مشتملة على دراسات فنية ورسم خرائط فذلك يتطلب جهدًا ومالًا، كما يخفف العبء على المشاركين؛ لأنه لولا إصداره لاحتاج كل واحد منهم إلى إجراء هذه الدراسة بنفسه.

الترجيح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الأول** ، القائل بجواز بيع كراسة الشروط لمن يرغب المشاركة.

- **قوة الأدلة:** لقوة ما استدل به أصحاب هذا الرأي، من عموم أدلة مشروعية البيع.
- **تحصيل المنفعة:** ولأن في شرائها تحصيل منفعة للمشارك؛ إذ يستفيد من المعلومات التي تحتويها الكراسة.
- **مقابل جهد مبذول:** كما أن المناقص له بذل مجهودًا يستحق عليه أخذ العوض، وعليه فهو يحقق مقصد الشارع في عدم أكل أموال الناس بالباطل.
- **شرط سائغ:** كما أنه شرط سائغ لا تأثير له في صحة العقد، وقد قال ﷺ: «المسلمون على شروطهم» .

المسألة الخامسة: حكم المطالبة بالضمان في المناقصات:

الضمان ومشروعيته: الضمان هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق فيثبت في ذمتهما جميعًا، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما، واشتقاقه من الضم، ومشروعيته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع: من الكتاب قوله تعالى: «وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ»، ومن السنة ما روى أبو أمامة قال: سمعت النبي ﷺ يقول في الخطبة عام حجة الوداع: «العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي»، والإجماع نقله ابن قدامة في المغني بقوله: وأجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة.

البيان وسبب الخلاف: الراغب في المشاركة يقدم مع عطائه ضمانًا يعرف بالضمان الابتدائي، ويهمل كل عرض لا يصاحبه ضمان، ويرد الضمان الابتدائي إلى أصحاب العروض الذين لم ترس عليهم المناقصة، أما من رست عليهم فإما أن يستكمل الضمان الابتدائي أو يسترد ويقدم ضمانًا نهائيًا. والسبب في البحث هو بيان حكم المطالبة بالضمانين، وهل هما مشروعان أم لا؟

1 الضمان الابتدائي:

هدفه وحكمه: الهدف منه التأكد من جدية المناقصين وصدق رغبتهم في الاشتراك والتزامهم بالتعاقد في حالة إرساء العطاء على أحدهم، وحكمه: **لا مانع شرعًا من المطالبة به** بناءً على أدلة مشروعية الضمان، وعملًا بقوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم»، وهو أمانة في يد المناقص له يرد إلى من لم ترس عليهم المناقصة، وهو ما أقره علماء مجمع الفقه الإسلامي؛ أما إذا سحب المناقص عطائه قبل إرساء المناقصة فإن مبلغ الضمان لا يرد لصاحبه، وهذا يشبه صورة من صور بيع العربون وهو أن يشتري أو يكتري سلعة ويعطيه شيئًا من الثمن على أنه إن كره البيع تركه للبائع وإن أحبه حاسبه به.

الرأي:	البيان:
الأول:	**منع بيع العربون**، وهو قول جمهور الفقهاء المالكية والشافعية ورواية للحنابلة.
الثاني:	**صحة بيع العربون**، وهو الصحيح من مذهب أحمد.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة من السنة والأثر والمعقول.

حديث عمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده أنه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع العربان»، وجه الدلالة: ظاهره تحريم البيع مع العربان لما فيه من الشرط الفاسد والغرر ودخوله في أكل المال بالباطل.

أثر عطاء وابن طاوس: روى ابن أبي شيبة عن عطاء وعن ابن طاوس عن أبيه: أنهما كرها العربان في البيع.

المعقول: أنه أكل لأموال الناس بالباطل، ولأنه شرط للبائع شيئًا بغير عوض، ولأنه بمنزلة الخيار المجهول.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة من الأثر.

أثر نافع بن عبد الحارث: روى عبد الرحمن بن فروخ: أن نافع بن عبد الحارث اشترى دارًا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن لم يرض عمر فأربعمائة لصفوان.

أثر ابن سيرين: روي عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسًا أن يعطي الرجل العربون الملاح أو غيره فيقول: إن جئت به إلى كذا وكذا وإلا فهو لك، وجه الدلالة: ظاهر الآثار جواز بيع العربون.

الترجيح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الأول**، القائل بمنع بيع العربون؛ لقوة أدلته، ولأنه أكل لأموال الناس بالباطل، لقوله تعالى: «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ».

قوة أدلة المنع: لقوة أدلة المنع، من حديث النهي عن بيع العربان، ومن أن فيه شرطًا فاسدًا وغررًا.

أكل المال بالباطل: ولأنه أكل لأموال الناس بالباطل، وقد نهى الله عنه في كتابه الكريم.

الأثر على الضمان الابتدائي: وبناءً على ذلك فإن **مصادرة الضمان المالي الابتدائي تعد من قبيل بيع العربون في صورة من صوره فلا يحق لصاحب المناقصة أخذه سواء ظفر المناقص بالعقد أم لا** .

٢ الضمان النهائي:

تعريفه وحكمه: يقدمه المناقص الذي رست عليه المناقصة خلال مدة محددة من تاريخ إصداره برسو المناقصة عليه والتزامه بالتعاقد، وحكمه: **يباح للجهة الداعية المطالبة به** ، ولا يختلف حكمه عن الضمان الابتدائي، فالغاية منه التزام المناقص بتنفيذ كافة شروط العقد في المدة المحددة دون تأخير أو مخالفة، كما أن مصادرته لا تجوز إلا إذا لم يف صاحبه بواجبه تجاه تنفيذ العقد وترتب على عدم وفائه ضرر مالي للمناقص له، وفي تلك الحالة يمكن المقاصة بين مبلغ الضمان النهائي وبين ما يجب على المناقص المتعهد من تعويض مالي.

المسألة السادسة: الضمان بخطاب ضمان مصرفي وحكم العمولة:

مفهومه وصوره: صورة من صور الضمان، وهو تعهد كتابي بناء على طلب العميل يلتزم فيه المصرف لصالح العميل في مواجهة شخص ثالث بدفع مبلغ معين في وقت معين، وعرفه د. بكر أبو زيد بقوله: «هو تعهد قطعي مقيد بزمن محدد غير قابل للرجوع، يصدر من البنك بناء على طلب طرف آخر (عميل له) بدفع مبلغ معين لأمر جهة أخرى مستفيدة من هذا العميل، لقاء قيام العميل بالدخول في مناقصة أو تنفيذ مشروع بأداء حسن، ليكون استيفاء المستفيد من هذا التعهد متى تأخر أو قصر العميل في تنفيذ ما التزم به للمستفيد في مناقصة أو تنفيذ مشروع ونحوهما، ويرجع البنك بعد ذلك على العميل بما دفعه عنه للمستفيد».

فائدته: حماية المستفيد من تنفيذ المشاريع أو تأمين المشتريات وفق شروط وأوقات محددة، ولا يقبل إصداره إلا إذا توافرت للبنك القناعة بكفاءة العميل المالية والمعنوية، ويتقدم أصحاب رؤوس الأموال إلى المصارف لأخذ خطاب ضمان عند طرح المناقصات بدلًا من وضع نقود تحجز عليه ولا يستفيد منها لمدة معينة، وفي المناقصات الدولية توفر خطابات الضمان على مقدم الضمان إجراءات تحويل العملة واستردادها وتحيه من خسائر هبوط أسعار العملة.

أقسامه من حيث الغطاء: خطاب بغطاء كامل بحيث يمثل الغطاء قيمة الخطاب، وخطاب بغطاء جزئي وهو بعض قيمة الضمان.

أقسامه من حيث الغرض: خطاب ضمان ابتدائي وهو لا يختلف عن الضمان من المناقص له ويمثل نسبة ضئيلة من حجم المشروع لا تتجاوز عشرة في المائة، وخطاب ضمان نهائي وهو تعهد من المناقص بعد التعاقد لتأكيد التزامه بتنفيذ العملية وفق الشروط والمواصفات المحددة.

كيفية إصداره: يتقدم طالب خطاب الضمان بطلب للبنك يحدد فيه مبلغ الضمان ومدته والجهة المستفيدة والغرض منه، ويجب أن يكون لدى البنك قبل إصداره القناعة بأن كفاءة العميل المالية والمعنوية كفيلة بالوفاء بالتزامه، وإذا كان مبلغ الضمان كبيرًا طلب البنك عادة تأمينات إما رهنًا عقاريًا مسجلًا أو رهن أسهم أو إيداع أوراق مالية أو كفالة بنك خارجي معروف، ويحتفظ عادة بتأمينات نقدية يودعها العميل بنسبة حوالي ٢٥٪ من قيمة الضمان وقد تزيد أو تقل تبعًا لمركز العميل وطبيعة المشروع.

الحكم الشرعي الأصلي: علاقة المصرف بالجهة المستفيدة علاقة ضمان وكفالة، والضمان جائز ومشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وعلاقة المصرف بالعميل تختلف حسب كون الخطاب له تغطية كاملة أم لا، وبالنظر إلى أقسام خطاب الضمان نجد أنها لا تخالف الضمان المشروع فقد تحققت فيها شروط الضمان من رضا الضامن وكونه أهلًا للتبرع وكون المضمون معلومًا حالًا أو مآلًا؛ أما الضمان بخطاب الضمان الابتدائي فهو ضمان لدين لم يجب حيث إن المناقص ليس مدينًا للجهة الإدارية بشيء، وبالتالي فإن ضمان البنك له يعد ضمانًا لما سيجب، وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء والراجح فيها قول جمهور الفقهاء حيث ذهبوا إلى جوازه للحاجة الداعية إليه.

الرأي:	البيان:
الأول:	**لا يجوز للمصرف أن يأخذ مقابلًا على إصدار خطاب الضمان** سواء كان له غطاء أم لا، وهو قول لبعض العلماء المعاصرين.
الثاني:	**يجوز للمصرف أخذ مقابل على إصداره** على اعتبار أنه عقد وكالة، وهو ما قال به بعض العلماء المعاصرين منهم د. زكريا البري.
الثالث:	**فرق بين ما إذا كان خطاب الضمان له غطاء أم لا** ، فإذا كان له غطاء جاز للمصرف أخذ الأجر نظير إصداره، وإن لم يكن له غطاء لم يجز أخذ مقابل لأجل إصداره لكن يجوز أخذه تكاليف الإصدار فقط أي بمقدار جهده وإجراءات عمله دون ربط الأجر بمقدار المبلغ الصادر به خطاب الضمان، وهو قول لبعض العلماء المعاصرين.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بثلاثة أوجه: أن خطاب الضمان المصرفي عقد كفالة وهو عقد من عقود الإرفاق والإحسان ولا يجوز أخذ الأجر عليه؛ وأن حقيقة الكفالة أنها دين على المكفول فإذا رده مع الزيادة فهو ربا؛ لأن المصرف سيدفع إلى الجهة الإدارية وسيأخذ زيادة فهو قرض جر نفعًا؛ وأن المصرف قد ينتفع بمبلغ الغطاء والغطاء من باب الرهن فكان انتفاع الضامن به محرمًا.

أدلة الرأي الثاني: أن الوكالة هي إقامة الغير مقام النفس في تصرف جائز معلوم وهذا موجود في خطاب الضمان فالعميل يوكل المصرف في أن يسدد عنه إذا لم يقم بتنفيذ العملية وأخذ الأجرة على الوكالة جائز؛ وأن المصلحة تقتضي إباحة أخذ الأجرة عليه وإذا كان مقتضى الضمان المصرفي إلزام المصرف بالمغارم فلم لا يكون له غنم من المضمون يؤديه العميل نتيجة الاتفاق والرضا.

أدلة الرأي الثالث: أن خطاب الضمان الذي له غطاء يعد كفالة ووكالة معًا: كفالة بالنسبة لعلاقة المصرف بالمستفيد ووكالة بالنسبة لعلاقته بالعميل، والوكالة تجوز بأجر وبغير أجر، وقد نوه بعض العلماء بما قاله ابن قدامة في المغني: ويجوز التوكيل بجعل وغير جعل؛ فإن النبي ﷺ وكل أنيسًا في إقامة الحد وعروة في شراء شاة وعمرًا وأبا رافع في قبول النكاح بغير جعل، وكان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم عمالة، فإن كانت بجعل استحق الوكيل الجعل بتسليم ما وكل فيه إلى الموكل؛ أما خطاب الضمان غير المغطى فإن علاقة المصرف بالعميل علاقة كفالة وعقد الكفالة من عقود الإرفاق فإذا اشترط الضامن شيئًا لنفسه خرج الضمان عن حقيقته فمنع لذلك.

الترجيح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الثالث** ، القائل بالتفريق بين كون خطاب الضمان له غطاء مالي أم لا؛ فإذا كان له غطاء جاز للمصرف أن يأخذ أجرًا لأن علاقته بالعميل علاقة وكالة وهي تجوز بأجر وبدون أجر، أما إذا كان غير مغطى فلا يجوز لما فيه من شبهة الربا.

- **قوة الأدلة:** لقوة أدلة أصحاب هذا الرأي، وظهورها في التفريق بين المغطى وغير المغطى.
- **عدم فتح باب الجشع:** كما أن في القول بذلك عدم فتح المجال لمن ليس لهم القدرة على الوفاء بالتزاماتهم في الدخول في المناقصات، وفيه حد من التعامل الجشع والتوسع في الأعمال مما ليس في استطاعة الإنسان القيام به.

الوقاية من الربا: وفي ذلك وقاية من أن يضطر العميل في النهاية إلى الخضوع لما تفرضه عليه المصارف من فوائد ربوية نظير قيامه بالسداد بمقتضى الضمان.

قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي – الدورة الثانية بجدة: جاء في قراره: أولًا: **أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان** والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته سواء أكان بغطاء أم بدونه، ثانيًا: أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزة شرعًا مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء.

من أسباب القرار: أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه، فإن كان بدون غطاء فهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالًا أو مآلًا وهذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الإسلامي باسم الضمان أو الكفالة، وإن كان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي الوكالة والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد المكفول له؛ وأن الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة؛ لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعًا على المقرض وذلك ممنوع شرعًا.

5 حكمة مشروعية المناقصة:

1. **أكبر منفعة بأقل تكلفة:** حصول المناقص له على أكبر منفعة بأقل تكلفة، وقد أشارت الشريعة إلى ذلك بقوله تعالى: «وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا» ، ولا شك أن المناقصة تحقق المنفعة بأقل تكلفة.

2. **الرقابة على النفقات العامة:** أن عقود المناقصات تشكل وسائل رقابة على النفقات العامة التي تقوم بها الدولة حتى لا تسيء استخدام الأموال العامة مما يؤدي إلى حفظ المال العام من العبث والإهدار.

3. **دفع التهمة:** أن عقود المناقصات تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة والخاصة بأقل التكاليف مع دفع التهمة عمن يباشرها خاصة إذا تعلق الأمر بالأموال العامة أو أموال اليتامى، ولذلك قد تتعين في الشراء أو إنجاز العمل لمؤسسات الدولة العامة كالمدارس والأوقاف أو المصالح المتعلقة بأموال اليتامى.

٤ **ضمان التنفيذ:** أن المؤسسات العامة والخاصة تسعى من خلالها إلى ضمان تنفيذ مشاريعها على الوجه المطلوب وفي الوقت المحدد بما يحقق المصلحة وفق أفضل الشروط وأقل الأسعار.

6 خصائص عقد المناقصة:

- **عقد رضائي:** يتوقف على رضا المناقص والمناقص له؛ لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» .
- **عقد معاوضة:** يقصد كل من المتعاقدين الحصول على منفعته مقابل عوض يبذله للطرف الآخر.
- **عقد إذعان:** ينفرد المناقص له بوضع شروطه مسبقًا وليس للمناقص إلا أن يقبل العقد كاملًا أو يرفضه كاملًا دون تعديل.
- **عقد مركب:** يتضمن مجموعة من العقود كبيع دفتر الشروط وعقد الضمان والعقد المتعلق بموضوع المناقصة.
- **عقد ملزم:** إذا تم إبرامه وجب على كل منهما الوفاء بما التزم به إلا إذا اتفقا على فسخه أو كان يتضمن شرطًا بذلك.
- **عقد محدد:** يحدد فيه المناقص سواء كان سلعة كما في التوريد أو عملًا ومنفعة كما في المقاولة تحديدًا دقيقًا يوصل إلى العلم به فهو ليس عقدًا احتماليًا كالجعالة.
- **عقد مستمر:** في الغالب ليس عقدًا فوريًا بل تحصل فيه المنفعة على فترات كالمقاولة ويستمر فيه البيع لفترة كالتوريد على مدى زمني معين.
- **عقد إجرائي:** يتم وفق منظومة إجراءات كالإعلان في الصحف ثم تقديم العطاءات إلى أن يتم إبرام العقد مع المناقص الفائز.
- **عقد مستحدث:** لم يكن معروفًا عند الفقهاء المتقدمين وهو جائز جريًا على أصل الإباحة.

7 الالتزامات المترتبة على عقد المناقصة:

أ التزامات المناقص:

1. **تنفيذ العمل:** تنفيذ العمل الذي تعهد به وفق الشروط والمواصفات المتفق عليها ما لم تكن مخالفة شرعية، لقوله ﷺ: «والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا» ، وإذا لم توجد شروط متفق عليها فالمرجع إلى العرف عند أهل كل صنعة.

2. **تسليم العمل:** تسليم العمل بعد إنجازه خلال المدة المحددة في العقد ما لم تكن قوة قاهرة تمنع التسليم ثم تسليمه إلى المناقص له بأن يخلي بين ما تعهد به وبينه على الوجه والمكان المتفق عليه، وفي حالة عدم التسليم منجزًا دون قوة قاهرة يكون مخليًا بالتزاماته مما يترتب عليه تحمل المسئولية والجزاءات الواردة في العقد.

3. **ضمان العمل:** ضمان العمل بعد تسليمه وهو ضمان حسن أداء المعقود عليه بعد التسليم مدة معينة.

ب التزامات المناقص له:

1. **تمكين المناقص:** تمكين المناقص من تنفيذ العمل بأن يمكنه من التنفيذ بعدم الحيلولة بينه وبين البدء، عملًا بقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» .

2. **دفع العوض:** يلتزم بدفع المقابل المالي للمناقص وفقًا لما تم الاتفاق عليه من المقدار والجنس والنوع وطريقة الدفع.

3. **تعويض الإضافات:** الحق في الحصول على تعويض إذا قام المناقص بعمل إضافات لم تطلب منه في العقد ولم يتم الاتفاق عليها، فإذا تبين أن هذه الإضافات مفيدة ولازمة تعين على المناقص له تعويضه مقابل ذلك، وقد أفتى بيت التمويل الكويتي: إذا كان في عقد المقاولة نص على أنه إذا جرت مسائل تقتضي المصلحة لإتمامها يكون السعر مثل ما ورد في العقد فعلى بيت التمويل أن يدفع للمقاول قيمة الأعمال التي جدت ويرجع بهذه الزيادة على العميل، أما إذا لم يرد نص فإن كانت المصلحة تقتضي وجوب هذه المسألة فإنه يحكم في ذلك العرف.

NAARA 01105405478

المسألة السابعة: حكم العجز عن تنفيذ عقد المناقصة بسبب الجائحة:

البيان وسبب الخلاف: لما كان تنفيذ عقد المناقصة يتم على مراحل زمنية متعددة فقد يقع في هذه المدة تغير جوهري في الأسعار نتيجة لقوة قاهرة أي حادث طارئ مثل حرب أو زلزال أو طوفان مما يترتب عليه الإخلال بميزان المعاوضة، وهذا ينطبق على حكم الجائحة في الفقه الإسلامي، والسبب في البحث هو بيان حكم ما يطرأ من تغير جوهري في التكاليف والأسعار بعد التعاقد مما يجعل تنفيذ الالتزام العقدي يلحق بالملتزم خسائر جسيمة، وهل يبقى الالتزام على أصله أم يجوز تعديله؟

الجائحة لغةً: مشتقة من الجوح وهو الاستئصال، يقال: جاح الشيء يجوحه استأصله، والجمع جوائح، ومنه اشتقاق الجائحة وهي المصيبة تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله، وهي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها وكل مصيبة عظيمة.

الجائحة اصطلاحًا عند الفقهاء: عرفها ابن عرفة بقوله: «ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرًا من ثمر أو نبات بعد بيعه»، وفي المجموع: هي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها، وفي المبدع: الجائحة كل آفة سماوية لا صنع للآدمي فيها كالريح والحر والبرد والعطش فكل ما تهلكه من الثمر على أصوله قبل أوان جذه فهو من ضمان البائع.

التوسع في التعريف: ومن خلال تعريفات الفقهاء نجد أنها جاءت مقتصرة على ما تلف من الثمار، بخلاف تعريفها لغةً فقد جاء عامًا في الثمار وغير الثمار، ولذلك وضع أحد الباحثين تعريفًا عامًا يشمل غير الثمار مفاده أن **الجائحة هي حدث عام طارئ أثناء تنفيذ العقد غير متوقع الحدوث وقت إبرامه ويتعذر دفعه أو تجنب آثاره مما يسبب خسارة فادحة للمدين إذا استمر في تنفيذ التزامه بشروطه السابقة** .

الحكم الشرعي في العجز بسبب الجائحة: فإذا عجز المناقص عن تنفيذ العقد كما لو حدثت ظروف طارئة بعد إرساء العطاء عليه وترتب على ذلك عجزه عن الوفاء بالتزاماته وفق شروط عقد المناقصة أو إرهاقه، **جاز له اللجوء للقضاء لتخفيف ذلك عليه** اعتمادًا على الرأي القائل بوضع الجوائح في الفقه الإسلامي.

دليل وضع الجوائح: قوله ﷺ: «لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك

أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» .

قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي: أولًا: **في العقود المتراخية التنفيذ كعقود التوريد والتعهدات والمقاولات، إذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد تبدلًا غير الأوضاع والتكاليف والأسعار تغييرًا كبيرًا بأسباب طارئة عامة لم تكن متوقعة حين التعاقد فأصبح بها تنفيذ الالتزام العقدي يلحق بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة من تقلبات الأسعار في طرق التجارة، ولم يكن ذلك نتيجة تقصير أو إهمال من الملتزم في تنفيذ التزاماته، فإنه يحق للقاضي في هذه الحال عند التنازع وبناء على الطلب تعديل الحقوق والالتزامات العقدية بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين** ، كما يجوز له أن يفسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه منه إذا رأى أن فسخه أصلح وأسهل في القضية المعروضة عليه، وذلك مع تعويض عادل للملتزم له صاحب الحق في التنفيذ يجبر له جانبًا معقولًا من الخسارة التي تلحقه من فسخ العقد بحيث يتحقق عدل بينهما دون إرهاق للملتزم، ويعتمد القاضي في هذه الموازنات جميعًا رأي أهل الخبرة الثقات، ثانيًا: ويحق للقاضي أيضًا أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال في وقت قصير ولا يتضرر الملتزم له كثيرًا بهذا الإمهال، هذا وإن مجلس المجمع الفقهي يرى في هذا الحل المستمد من أصول الشريعة تحقيقًا للعدل الواجب بين طرفي العقد ومنعًا للضرر المرهق لأحد المتعاقدين بسبب لا يد له فيه.

- **تحقيق العدل:** تحقيقًا للعدل الواجب بين طرفي العقد، فلا يُترك أحد الطرفين يحمل وحده خسارة سببها لا يد له فيه.
- **منع الضرر المفرط:** ومنعًا للضرر المرهق لأحد المتعاقدين بسبب لا يد له فيه، رفعًا للحرج عن الملتزم.
- **الاستناد إلى أصول الشريعة:** فالحل مستمد من أصول الشريعة، من قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»، ومن حديث الجائحة.

MNARA

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

السلسلة الأكاديمية الشاملة – مقررات الفرقة الثانية

دليل مذكرات السلسلة المعتمدة

★ **القضايا الفقهية المعاصرة** — هذا المقرر الحالي

- الفقه المقارن (عبادات) — متاح بالتطبيق
- مبادئ علم الاقتصاد — متاح بالتطبيق
- المنظمات الدولية — متاح بالتطبيق

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثانية

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478